

secución es, aparte de la anualidad de la acción (después del año corresponde también aquí una acción *in factum*, según parece dentro de los límites del enriquecimiento), también la facultad del demandado de liberarse de la condena restituyendo al actor la cosa o utilidad conseguida³⁵. La *exceptio*, en fin, que no está sujeta a las limitaciones de tiempo propias de la acción; puede ser opuesta, análogamente a la *exceptio doli*, contra quien pretenda la ejecución del negocio arrancado con violencia³⁶.

FRANJA MORADA

se ejerció, y que el carácter de acción *in rem scripta* le haya sido conferido por los compiladores bizantinos por imitación del modo de funcionamiento de la *in integrum restitutio*; contra esta doctrina, MAIER, *op. cit.*, ps. 91 y ss.

³⁵ La opinión común es que la restitución pueda tener lugar como consecuencia de un *iussus* del juez, después de la verificación de la violencia cometida; en sentido contrario, BIONDI, *Studi sulle "actiones arbitrarie"* (1913), ps. 38 y ss., quien considera que sólo faltando la restitución el pretor concedía la fórmula. La cuestión está todavía *sub iudice*, no obstante la enérgica defensa de la *communis opinio* por parte de LENEL, *Zur Lehre von den "actiones arbitrarie"* [Sobre la doctrina de las "*actiones arbitrarie*"], en "*Festschrift für R. Sohm*", 1914, ps. 209 y ss.

³⁶ Contra la opinión repetidamente expresada en estos últimos años, según la cual en los negocios no solemnes la violencia habría tenido por consecuencia la nulidad absoluta, véase C. LONGO, "*Bull. Ist. Dir. Rom.*", nueva serie, 1, 1935, ps. 68 y ss.; y BETTI, *Dir. rom.*, 1, 309, n° 2, 313 y ss.

CAPÍTULO IV

DEFENSA DE LOS DERECHOS: EL PROCESO PRIVADO

Al definir las normas jurídicas (ps. 17 y ss.) hemos visto que entre sus características figura la sanción, es decir, que un mal o la pérdida de un bien amenaza a sus trasgresores; y se ha agregado que para la ejecución de tal amenaza en las hipótesis particulares, existe un aparato de normas secundarias que regulan la actitud que debe observar, como consecuencia de la trasgresión, el trasgresor mismo u otros de los coasociados. Por regla (y la regla está tanto menos sujeta a excepciones cuanto más avanzada la civilización), la más o menos compleja actividad necesaria para la aplicación de la sanción está no sólo regulada por el Estado, sino también desarrollada por sus órganos o bajo el control de éstos; y a tal actividad se le da el nombre de proceso.

Corresponde, sin embargo, distinguir dos tipos de procesos: aquellos en los cuales la verificación del hecho antijurídico, la determinación y la efectiva aplicación de la sanción son requeridas y controladas por personas que por su función, permanente u ocasional, representan el interés colectivo (es decir, por funcionarios o por ciudadanos que ejercen la acción popular); y aquellos en que igual actividad es desarrollada por el particular titular del derecho subjetivo violado (cfr. p. 20). Tal es la distinción que hoy se establece entre proceso penal y civil. En el derecho romano la distinción se plantea, en cambio, entre proceso público y proceso privado: sea porque el adjetivo *civilis* adquiere sólo en época bastante avanzada (y muy de tiempo en tiempo) un significado antitético a *criminalis*, sea —y sobre todo— porque, mientras en el derecho moderno el requerimiento de la pena parte

siempre de la autoridad pública, el mundo romano distingue también las penas en públicas y privadas, según sean infligidas a instancia pública (iniciativa del magistrado, acción popular) o a solicitud del interesado, y que su eventual provecho sea para el Estado o para el interesado mismo (cfr. cap. XVI).

Por consiguiente, podemos definir el proceso privado romano como la actividad desarrollada por las partes de una relación jurídica privada, una de las cuales afirma la violación del propio derecho para conseguir, con el concurso de los órganos del Estado, una declaración incontestable sobre la existencia o inexistencia de la violación y, en caso afirmativo, la aplicación de la sanción.

La expresión *proceso privado* se ajusta, por otra parte, al proceso privado antiguo y al clásico también por otros criterios; es decir, por la importancia preponderante que la actividad de las partes asume frente a la del magistrado jussdicente, y por el hecho de que la función de este último se limita a auxiliar a las partes en el planteamiento de la controversia, y casi a poner el sello de su autoridad sobre las declaraciones de aquéllas, mientras que la decisión es remitida a un *iudex privatus*, elegido o, por lo menos, aceptado por las partes mismas. En este sentido, alguien contrapone al proceso clásico el de la época posterior, dando a este último el nombre de proceso público; pero nosotros evitaremos semejante terminología, considerando mucho más importante, como criterio de distinción entre proceso público y privado, la consideración del sujeto por quien se pone en movimiento la actividad jurisdiccional.

Si en el estudio del derecho vigente el proceso civil puede ser separado del derecho privado (o, como habitualmente se dice, material), ello no es posible en el estudio del derecho romano. La concepción moderna de las relaciones jurídicas hace que éstas puedan ser descritas en su estado de pacífico goce y actuación, y que su violación y la consiguiente aplicación de la sanción tengan importancia subsidiaria; mientras que el desarrollo de las instituciones jurídicas romanas ha tenido su punto de partida en ciertos períodos históricos, más en el medio de defensa concedido a quien se hallase en determinadas situaciones, que en las relaciones de

derecho material consideradas en sí mismas. La ley de las XII Tablas está totalmente fundada sobre las relaciones de derecho material que nacen de tal o cual hecho o negocio jurídico, y sobre sus modificaciones y extinción; los medios de defensa contra los trasgresores están en segunda línea. En cambio, el edicto pretorio, que en la evolución del derecho romano es un factor de importancia no inferior, no contiene —y no puede por su naturaleza contener— ni concesión de derechos subjetivos ni imposición de obligaciones, pues sólo es una fuente de medios judiciales, dispuestos a fin de proteger tanto las relaciones ya reconocidas por el *ius civile*, como otras que son consideradas de mero hecho; en este último caso, los medios procesales no son un *posterius* respecto a normas primarias por ellos defendidas, sino el *prius*, y sólo como consecuencia de una lenta adaptación de la conciencia social las situaciones que hemos llamado de mero hecho van asumiendo, a través de la protección judicial, el carácter de negocios y relaciones jurídicas y de consiguientes trasgresiones. Por otra parte, también después de cumplida esta última evolución, la perfección de los medios técnicos acordados hizo que sobre ellos se concentrase con preferencia la atención de la jurisprudencia clásica; la cual no acostumbra a preguntarse si subsiste uno u otro derecho u obligación, sino si y qué medio judicial compete a quien haya recibido esta o aquella lesión. Por lo tanto, el estudio del derecho privado romano tiene como presupuesto necesario el conocimiento del proceso.

Este conocimiento faltó, en gran parte, a los romanistas anteriores al siglo XIX, porque la profunda diferencia existente entre el derecho clásico y el justiniano había hecho, en esta materia más que en otras, que los textos del *Corpus iuris* suprimieran toda referencia precisa al primero, y describiesen también el segundo bastante deficientemente.

Una rica fuente de conocimiento fué ofrecida, para el proceso clásico, por el descubrimiento de las Instituciones gayanas, cuyo libro IV se refiere a las acciones. Para el proceso de la más avanzada época imperial, se recogen noticias numerosas de fuentes diversas, y en particular de los papiros greco-egipcios.

Las diferencias profundas que hay entre los distintos tipos históricos de proceso romano no admiten una exposición unitaria al respecto; ésta tiene que desarrollarse, necesariamente, separando

los tres sistemas de las *legis actiones*, de las *formulae* y de la *cognitio extra ordinem*¹.

§ 1. LAS "LEGIS ACTIONES"

La *actio* como declaración de parte: ¿*legis actiones* o simplemente *actiones*? La originaria defensa privada y la intervención del magistrado. Acciones ejecutivas y acciones declarativas; el proceso *in iure* y *apud iudicem*. La *litis contestatio* y sus efectos. Las dos *actiones* primitivas: *manus iniectio* y *sacramentum* (*in rem* e *in personam*). Acciones posteriores o excepcionales: *iudicis postulatio*, *condictio*, *pignoris capio*.

La más antigua forma de proceso toma su nombre de las declaraciones solemnes del propio derecho hechas por las partes o por una de ellas, por lo común en el tribunal del magistrado (*in iure*), y algunas veces también en otro lugar (*ex iure, extra ius*). Tales declaraciones, que en sus formas originales habían precedido a cualquier ley escrita, llevaban al principio el simple nombre de *actiones* (quizá en el sentido de escenas públicamente recitadas); pero la ley de las XII Tablas y las otras que la siguieron fijaron muchos detalles del desarrollo del proceso antes y después de la declaración solemne, determinaron la *actio* mediante la cual relaciones jurídicas nuevamente reconocidas podían hacerse valer y crearon también alguna nueva *actio*. Cuando la estructura del

¹ Las exposiciones de KELLER (*Il processo civile rom. e le azioni*, 1852, 6ª ed., dirigida por WACH, 1883; trad. ital. de la 3ª ed., de Filomusi-Guelfi, 1870) y de BETHMANN-HOLLWEG (*Der Civilprozess des gemeinen Rechts* [El proceso civil del derecho común], vols. I a III: *El proceso civil romano*) son anticuadas. Dignamente las sustituye hoy el hermoso libro de WENGER, *Inst. des röm. Zivilprozessrechts* [Instituciones de derecho procesal civil romano], Monaco, 1925, ya traducido al italiano por ORESTANO (Milano, 1938) y al inglés por HARRISON FISK (New York, 1940). En Italia la mejor exposición de conjunto es siempre la de SCIALOJA, *Procedura civ. rom.*, 2ª ed., Roma, 1936, ordenada como comentario al libro IV de GAYO. En los manuales escolásticos, el procedimiento está a menudo sacrificado o recíprocamente rechazado como en el juego de pelota, entre los de Instituciones y los de Historia; elogiable excepción es la de los autores franceses, que de conformidad con los programas oficiales universitarios dedican al proceso una parte adecuada (véase, por ejemplo, el reciente *Manual* de MONIER, I, 1ª ed., ps. 150 a 247); otro tanto hace BONFANTE en la *Storia del dir. rom.*, a partir de la 3ª ed. (1923). Las líneas que preceden explican por qué el estudio del proceso debe, en mi opinión, ser parte integrante de las Instituciones.

proceso cambió para tomar como base no ya la declaración solemne sino la fórmula (*infra*, § 2), se quiso distinguir a las *actiones* del nuevo tipo de las antiguas, y con referencia a la ley de las XII Tablas, falsamente considerada como fuente de todo el derecho más antiguo, se habló de *legis actiones*². La tradición recuerda, por lo demás, que la formulación de las *actiones* no se encontraba en las leyes, sino que era confiada a la magistratura sagrada de los pontífices, a la que las partes debían requerir previamente los formularios a recitar: sólo a partir del fin del siglo IV a. C., las acciones fueron divulgadas, y después lentamente retocadas, cuando la necesidad lo exigía, por la jurisprudencia laica.

La derivación del nombre de *agere*, y su aplicación exclusiva a la actividad de las partes, a la vez que produce de inmediato una clara sensación de la máxima importancia de tal actividad en la conducción del proceso, lleva con el pensamiento a una época primitiva, en la cual, no interviniendo todavía la Ciudad en la decisión de las controversias, éstas encontraban su resolución en la defensa privada: en el acto del acreedor, o de quien de otro hubiese recibido un daño, que tomaba por el cuello a su deudor; en el acto de los contendientes en torno a la propiedad de una cosa que trataban recíprocamente de arrebatarse. Las más antiguas *actiones*, la *manus iniectio* y la *legis actio sacramenti in rem*, no representan nada más que la formalización o estilización de estos gestos elementales de defensa del propio derecho; y la distinción entre *actio in personam* y *actio in rem* (acción sobre la persona y acción sobre la cosa) responde mucho mejor al desarrollo de estos litigios primitivos que a las normas del proceso clásico o justiniano.

La intervención del magistrado (que es invariablemente requerida en todas las *legis actiones*) se reduce, por lo menos en la época primitiva, al control de la actividad de las partes; y sólo aquí y allí se le confía también la misión de representar, frente a un simulacro de lucha que las partes ponen en escena, la autoridad ciudadana que quiere que la competencia se decida en el sentido que responda al mejor derecho, según ocurre en la frase *mitte ambo rem (hominem, equum, etc.)* que el magistrado debe pronunciar en ocasión de la *l. a. sacramenti in rem*, después que am-

² Es por eso bien visible en la exposición gayana la tendencia a tratar de la aplicación de cada *legis actio* con relación a las leyes, con algún descuido para los casos en que hay que buscar la fuente en la costumbre.

bas partes hayan puesto la simbólica ramita sobre la cosa que cada una afirma ser suya. Magistrado *apud quem legis actio est* fué probablemente, en los orígenes, el rey; después, el dictador; sucesivamente los dos *praetores* ordenados como magistratura colegiada, los mismos a quienes más tarde se dió el nombre de cónsules; y finalmente, desde el siglo IV a. C. en adelante, el *praetor minor*, a quien quedó reservada la función de regular el planteamiento de las controversias entre los particulares (*iurisdictio*)³.

El fin a que tiende la *actio* es diverso: a veces persigue el propósito único de solemnizar y legalizar el comienzo de una actividad totalmente propia del actor, que trata de realizar en el hecho un derecho ya verificado o considerado como tal, y que se desarrollará, por consiguiente, en adelante, por lo menos normalmente, sin la ulterior intervención del magistrado o de extraños (acciones ejecutivas); otras, en cambio, expresa las pretensiones de las partes sobre la existencia o inexistencia de derechos y obligaciones, y tiende a obtener su verificación (acciones declarativas). Pero también en esta última hipótesis la actividad del magistrado judicante se limita a vigilar a las partes en el planteamiento de la controversia: la decisión de ésta (*sententia*) con el previo examen de las pruebas aportadas por las partes, investigación que es, a la vez, de hecho y de derecho, es remitida a uno o más jueces, que son ciudadanos particulares. De aquí la distinción, que permanecerá en vigor también en la época del procedimiento formulario, entre dos estadios del proceso declarativo: el primero *in iure* (donde *iur* = tribunal del magistrado), el segundo *apud iudicem*; el primero destinado a plantear la controversia, el segundo a decidirla. El proceso *in iure* se cierra con la *litis contestatio*, consistente en que las partes llaman a los presentes como testigos de las declaraciones ya hechas, invitándolos a conservarlas en la memoria para referirlas *apud iudicem*. Ya en esta época, la *litis contestatio* debió vincular definitivamente a las partes a las declaraciones prestadas e impedir que la cuestión ya deducida en juicio volviera a proponerse (*bis de eadem re ne sit actio*).

Es juez (*iudex*), como se ha dicho, un particular elegido de común acuerdo entre las partes; pero parece que ya en la época

³ Para la probable sucesión de estas magistraturas, cfr. *Storia*, 5ª ed., ps. 27 y ss.

que estamos tratando hubiese en el tribunal un *album* de jueces, y que, cuando los contendientes no tuviesen ya preparado otro nombre, el magistrado los invitase a elegir en el *album*, y en caso de desacuerdo librase la extracción a la suerte. No de otra manera se procedía en ciertos casos en los cuales, por existir entre las partes más un conflicto de intereses que un litigio propiamente dicho, el juez tomaba el nombre de *arbiter*. Y las cosas no cambiaban ni siquiera allí donde leyes y costumbres (o quizá, también, el deseo de las partes) elevaban a tres el número de los que debían decidir. Verdaderos colegios judiciales son los de los *centumviri* y de los *decemviri stlitibus iudicandis*: la competencia de los primeros es indudable en materia de herencia, la de los segundos en materia de libertad y esclavitud, mientras que se discute acerca de su competencia en otros tipos de controversia⁴.

*
* * *

GAYO (IV, 12) enumera cinco *legis actiones*: *per sacramentum*, *per iudicis postulationem*, *per condictioem*, *per manus iniectioem*, *per pignoris capionem*. Las tres primeras son, en el sentido examinado, declarativas, e instauran controversias a decidirse *apud iudicem*; las dos últimas inician una actividad autónoma del actor sobre la persona o los bienes del demandado; es decir, son acciones ejecutivas⁵.

De todas ellas, la más antigua es quizá la *manus iniectio*.

Su presupuesto más común es la sentencia de condena al pago de una suma de dinero, ya pronunciada por un *iudex privatus*⁶.

⁴ F. BOZZA, *Sulla competenza dei centumviri*, Napoli, 1928.

⁵ La exposición gayana está gravemente mutilada en el manuscrito veronés, donde faltan largos fragmentos dedicados a la *l. actio sacramenti*, todo el pasaje sobre la *l. a. per iud. post.*, y buena parte del relativo a la *condictio*. Uno de los fragmentos encontrados en 1933 en Egipto (cfr. p. 11, n. 7) ha colmado la laguna relativa a la *iud. post.* y a la *cond.* haciendo justicia a muchas conjeturas de la doctrina precedente.

⁶ Así, por lo menos, en la época histórica; pero ciertamente la *m. i.* es más antigua que la moneda. Para algún vestigio de aplicaciones primitivas, no reconocidas más como tales en época avanzada, ver mi estudio sobre *La répression du vol flagrant et du non flagrant dans le très ancien droit romain*, en "Al Qanûn wal Iqtisad" (Revista de la Facultad Jurídica Egipcia), 2, 1932, ps. 109 y ss. (= *Rariora*, Roma 1946, ps. 197 y ss.).

Después de treinta días de tregua (*dies iusti*), el acreedor tiene el derecho de aprehender al deudor dondequiera que lo encuentre, y de conducirlo ante el pretor; aquí, repitiendo el gesto, declara: "*quod tu mihi iudicatus (o damnatus) es sestertium X milia, quandoc non solvisti, ob eam rem ego tibi sestertium X milium iudicati manum inicio*". Después de esta declaración solemne, que es la *actio*, el magistrado, si no encuentra irregularidades en el procedimiento, pronuncia (según parece) el verbo *addico*, con lo que el acreedor queda autorizado para llevar al deudor a su casa, para mantenerlo ligado durante 60 días con cadenas de 15 libras de peso, alimentándolo (cuando el deudor no se procure el sustento de otra manera) con una libra de farro al día; tiene, sin embargo, el deber de conducirlo a tres mercados consecutivos y de proclamar públicamente la condición de su prisionero y la suma de que es deudor. Si nadie se presenta en estas ocasiones a rescatar al desdichado, éste puede ser vendido como esclavo en la orilla opuesta del Tiber o dársele muerte; si los acreedores son varios, se distribuyen entre sí, a título de venganza, los trozos del cadáver, y un versículo de las XII Tablas tiene el cuidado de excusar a aquéllos por la eventual desproporción entre los trozos cortados por cada uno y el monto de los créditos.

El caso de la sentencia no es el único en que procede la *manus iniectio*: las XII Tablas la declaran ejercible también contra el que ha confesado *in iure* una deuda de dinero⁷. Y otras leyes admiten su aplicación para hacer valer créditos especiales por considerarse como títulos ejecutivos. Así el crédito del fiador que habiendo pagado por el deudor principal, puede pretender el doble de la suma entregada; así el crédito de aquel a quien un determinado rédito o suma haya sido legada *per damnationem*, es decir, con la fórmula *Titius heres meus Seio damnus esto dare*; así, a la inversa, el crédito del heredero contra el legatario que haya percibido un legado de valor superior a los mil ases (*lex Furia testamentaria*):

⁷ No se está, en cambio, de acuerdo en la interpretación de la frase *manus iniectio esto*, usada en las XII Tablas respecto del demandado que rehusa seguir al actor en el acto de la *in ius vocatio*. En efecto, es posible que la frase aluda simplemente a la facultad del actor de conducirlo por la fuerza al tribunal. Se entiende que si ante el pretor persistiese en la misma actitud, sería un *confessus* pasible de *m. iniectio* propiamente dicha (naturalmente, después de los *triginta dies iusti*).

así el crédito del dueño de una cosa contra quien la haya destruido o dañado (*lex Aquilia de damno*).

A las consecuencias de la *manus iniectio* típica, que es aquella que deriva de la sentencia y de las hipótesis procesales equiparadas, no puede sustraerse el deudor sino pagando la suma debida; puede, sin embargo, interceder en su favor un *vindex*, que ofrezca por lo menos igual garantía de solvencia. Por las fuentes sabemos que el *vindex* ejerce su función *in iure*, inmediatamente después de la declaración solemne del acreedor, y que él declara injustificada la *manus iniectio*; la noticia debe indudablemente completarse en el sentido de que el proceso, de ejecutivo se hace declarativo, colocándose al acreedor ante el cargo de probar las circunstancias que apodóticamente había afirmado desde el principio. De todas maneras, con la intervención del *vindex*, el deudor es puesto fuera de la causa; si la prueba no satisface, el acreedor ejerce una nueva *manus iniectio*, por el doble, sobre el *vindex*. Pero no en todas las hipótesis a que la *manus iniectio* fué extendida se aplican reglas idénticas; antes bien, mientras en algunos casos el régimen permaneció exactamente igual al de la *manus iniectio iudicati* (de donde el nombre de *m. i. pro iudicato*), en otros se diversificó en el sentido de que fué lícito al deudor *manum sibi depellere et pro se lege agere* (GAYO, IV, 24), es decir, transformar el proceso de ejecutivo en declarativo, sin la intervención de un *vindex*, pero siempre bajo la amenaza de la ejecución *in duplum* en caso de sucumbir; de esta más moderna *manus iniectio*, que fué llamada pura, amplió su aplicación una ley Vallia, reduciendo a estrechísimos límites los casos de *m. i. pro iudicato*.

*
* *
*

Quizá tan antigua como la que acabamos de estudiar es la *legis actio sacramenti*, por lo menos en su forma *in rem*. El nombre deriva de la circunstancia de que la litis versa no directamente sobre las pretensiones de las partes, sino sobre la promesa (*sacramentum*) que hacen ambas de pagar al erario una suma en caso de que la prueba de la afirmación principal no satisfaga. El juicio recae sobre el punto *utrius sacramentum iustum, utrius iniustum*

sit, es decir, sobre cuál de los dos tiene la obligación de entregar esa suma, con lo que se resuelve implícitamente la cuestión fundamental.

La *legis actio sacramenti* se desarrolla *in iure*, a través de todo un diálogo. Si la acción se intenta *in rem*, ambas partes afirman (sucesivamente, o quizá contemporáneamente) ser propietarias de la misma cosa, o herederas del mismo difunto, o titulares de la misma potestad familiar, o bien una afirma la libertad del hombre que la otra pretende su esclavo, una afirma el usufructo o la servidumbre predial que la otra niega; el objeto de la controversia, presente *in iure* o representado por cualquiera de sus partes o elementos (la casa por una teja, el fundo por un terrón, la herencia por un objeto que le pertenezca, etc.), es tocado por ambas partes con una ramita, en reemplazo de la lanza que es el símbolo de todo dominio o potestad. Después de la orden dada a ambas partes de dejar libre la cosa (p. 126), el magistrado concede la posesión interina (*vindiciae*) a aquella que *prima facie* parece merecer más confianza; sin embargo, es necesario que la restitución de la cosa y de los frutos, en la hipótesis de resultar vencida, sea garantizada a la otra parte mediante *praedes* (*pr. litis et vindiciarum*). Inmediatamente después (o quizá inmediatamente antes), las partes se provocan recíprocamente al *sacramentum*, que es de cincuenta ases si la cosa vale menos de mil, de quinientos si más; también para el pago de las sumas así prometidas se presentan al magistrado garantes, *praedes sacramenti*. Con esto se cierra la *legis actio*⁶; ahora las partes contestan la litis, y se dan cita ante el juez por ellas elegido o aceptado, o —si es del caso— ante los centunviros o decenviros: *apud iudicem* cada uno de los contendientes alega las pruebas del derecho invocado, y el juez, después de haberlas

⁶ La descripción se ha hecho de conformidad con GAYO, IV, 16 y 17; pero después de estos dos párrafos el manuscrito tiene una laguna; y no es improbable que allí se contemplaran hipótesis en las cuales el procedimiento fuera algo diverso. Parece, por ejemplo, que en un primer momento las litis que tuvieran por objeto un inmueble exigieran un simulacro de lucha sobre el lugar, y que a éste se refiera la *ex iure manum consertum vocare*, recordada por CICERÓN, *pro Mur.* 12, 26, y por otros clásicos. También es posible que originariamente no tuviese lugar la concesión de la posesión interina a uno entre los contendientes, sino que la cosa se le confiase al juez mismo.

valorado, dicta la *sententia*, en la que declara cuál *sacramentum* es *iustum* y cuál *iniustum*⁹.

Un poco diferente es el trámite de la *l. a. sacramenti in personam*. Aquí no tenemos dos afirmaciones de derecho, iguales y contrarias, sino por una parte la afirmación de un crédito, por la otra la negación de la deuda correspondiente; por eso, aun cuando la *legis actio* consiste todavía en un diálogo, sin embargo los nombres de *actio* y de *actor* son usados exclusivamente para indicar el ataque que el acreedor dirige contra el deudor, mientras que a la actitud negativa de éste (demandado) se la concibe como mera defensa (*is qui negat, qui se defendit*). Estas actitudes se revelan desde el estadio preparatorio de la *actio*: las partes no se presentan al magistrado de común acuerdo, sino que es el actor que *in ius vocat* al demandado, y éste está obligado, salvo raras excepciones, a seguirlo hasta allí¹⁰. *In iure* el actor afirma la existencia de la deuda (por ejemplo, *aio mihi a te furtum factum esse paterae aureae*, ob *eamque rem te mihi pro fure damnum decidere oportere*), el demandado la niega (*nego tibi a me furtum factum esse*, etc.), y sobre estas declaraciones se funda el acostumbrado *sacramentum*, con la intervención de los respectivos *praedes*; juzgando *utrius sacramentum iustum, utrius iniustum sit*, el juez habrá decidido implícitamente sobre la deuda. Es bastante incierto cuál era el campo de aplicación de la *l. a. sacramenti in personam*: entre las relaciones de deuda y de crédito están, indu-

⁹ La naturaleza de los derechos en discusión en la *l. a.* en examen puede hacer que las aserciones de las partes sean ambas disconformes con la verdad: por ejemplo, que no sea propietario ninguno de los litigantes, sino un tercero. Hay quien considera que en tal caso el juez debía declarar *iniusta* ambos *sacramenta*. Pero, ¿qué sucedería con la cosa controvertida? Más probable es que el juez se contentase con indagar cuál entre las dos partes tuviese comparativamente la situación mejor, y que el *sacramentum* de ésta fuese declarado *iustum*. Esto no puede llevar a consecuencias dañosas, porque la decisión solamente causa estado entre las partes, y el verdadero propietario puede siempre intentar contra el vencedor una nueva litis.

¹⁰ Consideramos con muchos otros que la *in ius vocatio* fuese propia de la *a. in personam*; y que el proceso *in rem* se iniciase siempre de acuerdo entre las partes, cansadas de disputar con medios materiales, a cuyo ejercicio, por otra parte, el derecho objetivo imponía los límites más allá de los cuales se incurre en el delito. En todo caso, está excluido que la actitud hostil o pasiva de quien era invitado a participar en la *a. in rem* autorizase al adversario a la *manus iniectio*; más bien se debería pensar que se le permitiese tomar la cosa controvertida de viva fuerza.

dablemente, excluidas las que hemos visto protegidas por la *manus iniectio*; entre los casos más seguros está el de la acción de hurto no flagrante, a la que se refiere dicho ejemplo, con hipótesis análogas, como la acción contra el tutor legítimo malversador (*actio rationibus distrahendis*); pero también la estipulación ha tenido en los orígenes el mismo régimen procesal, y otro tanto parece que debiera decirse con respecto al mutuo, aunque sólo más tarde haya sido reconocido como fuente de obligatio.

La decisión sobre la apuesta, si resuelve implícitamente el punto de derecho controvertido, no basta sin embargo, en muchos casos, para satisfacer las razones de las partes; este resultado se obtiene automáticamente sólo cuando, en la *actio in rem*, la decisión se emite en favor de quien obtuvo la posesión interina, o cuando, en la *actio in personam*, se declara inexistente la deuda. Una hipótesis sobre la cual estamos plenamente informados, es aquella en que la *actio in personam* hubiera conducido a un pronunciamiento afirmativo acerca de la existencia de una deuda de dinero: se aplica aquí, después de treinta días de tregua, la *manus iniectio*. Pero, ¿qué sucederá si la deuda reconocida no es de dinero, o si la litis de propiedad o potestad se decide en favor de la parte que no está en posesión? Ciertamente el derecho romano no da la acción ejecutiva para pretensiones que no sean liquidadas en dinero¹¹; y, en consecuencia, por lo menos para las relaciones obligatorias, parece seguro que sobre el proceso de comprobación, ya descrito, se injertase un nuevo proceso destinado a la estimación, al que debería referirse el nombre, que se encuentra en viejos textos, de *arbitrium liti aestimandae*¹². Más inciertas son las conse-

¹¹ Por lo menos, repetimos todavía una vez más, en época histórica; cuál fuese el régimen anterior a la introducción del dinero, podemos solamente entreverlo para algunas hipótesis particulares (cfr. el escrito citado en p. 127, n. 6).

¹² Mientras se ignoró la exposición gayana de la *l. actio per iudicis postulationem*, se pensaba que precisamente la *arb. liti aestimandae* fuese uno de sus casos de aplicación. Hoy causa mucha impresión no ver mencionada esta hipótesis en el pasaje recuperado: se puede pensar que el silencio sobre el particular derive, conforme a lo observado en la p. 125, n. 2, de la circunstancia de que se trataría de una aplicación no legal sino consuetudinaria; o todavía se puede conjeturar que tratándose de un procedimiento complementario al de la *legis actio sacramenti*, los juristas no la hayan considerado como acción autónoma. Pero hay que señalar, en fin, también la posibilidad de que el acreedor reconocido como tal haya tenido la facultad de ejercer, sin más, la *manus iniectio* por la suma que,

cuencias de la *actio in rem*; quizá estaba permitido al vencedor tomar la cosa dondequiera que la encontrase; más probablemente se procedía en forma ejecutiva contra los *praedes litis et vindictiarum* por la suma correspondiente a la valoración del actor, salvo los incidentes que sobre el particular podían provocar los ejecutados. Un versículo mutilado de las XII Tablas se refiere a un proceso de valoración respecto de los frutos percibidos por el poseedor interino: se nombraba un colegio de tres árbitros, que establecía el valor de los frutos percibidos y condenaba al vencido (¿originariamente los *praedes*?) a pagar el doble.

*
* *
*

La *manus iniectio* y el *sacramentum* son acciones indudablemente primordiales, en el sentido de que no es concebible un momento en que una de las dos faltase (salvo la primitiva defensa privada, no regulada de ningún modo por el derecho). Las otras tres —*iudicis postulatio*, *condictio*, *pignoris capio*— son complementarias: inventadas las dos primeras, declarativas, en sustitución de la *actio sacramenti*, sea por la imposibilidad de recurrir en ciertas hipótesis a una apuesta, o para ofrecer en otros casos a la elección de las partes medios menos arriesgados o más adecuados; sustitutiva la tercera, en algunas hipótesis particulares, de la *manus iniectio*.

A propósito de la *legis actio per iudicis postulationem*, sabíamos por la *lex Rubria de Gallia Cisalpina* (c. 23), y ahora un fragmento recuperado de GAYO lo confirma, que se recurría a ella cuando varios herederos o varios condóminos de una cosa o los propietarios de fundos limítrofes solicitaban *in iure* que se les diese un juez para la división de la herencia o de la cosa común o para la regulación de los límites (acciones *familiae erciscundae*, com-

según su propia estimación, representaba el valor de la prestación, en cuyo caso el deudor habría podido hacer oposición (en forma que ignoramos) respecto a la simple valoración; que discusiones incidentales de este género pudiesen suspender el procedimiento de la *m. i.* debería resultar indiscutiblemente de su casi segura aplicación a créditos que no habían sido objeto de una previa estimación oficial, y en particular al caso de la *lex Aquilia* (p. 129).

muni dividundo, finium regundorum). Evidentemente, la falta de una controversia propiamente dicha impedía recurrir, particularmente en los dos primeros juicios, a la *l. a. sacramenti*; la solicitud del juez debía ser presentada de común acuerdo por los interesados en la división al magistrado, sin que hubiese lugar a distinguir entre actores y demandados, ni entre pretensión y defensa.

Pero el nuevo texto gayano muestra que no en todos los casos de procedimiento *per iudicis postulationem* concurrían los mismos extremos; antes bien, en presencia de verdaderas controversias, razones de política legislativa podían llevar a evitar aquella pena que para el vencido representaba la *summa sacramenti*. Así, las XII Tablas disponían que se pudiese recurrir a nuestra *legis actio* para los créditos procedentes de estipulación; y GAYO nos da el texto de las declaraciones formuladas por las partes. La afirmación del crédito por parte del actor y la denegación de la deuda por parte del demandado correspondían, poco más o menos, a cuanto se ha dicho sobre la *l. a. sacramenti in personam*; pero en lugar de provocar al *sacramentum*, el actor se dirigía sucesivamente al adversario y al pretor diciendo: *Quando tu negas, te praetor iudicem (o arbitrum) postulo uti des*. Y el nombramiento tenía lugar inmediatamente. Considérase, sin embargo, que ya anteriormente los mismos créditos fuesen perseguibles con la *l. a. sacramenti in personam*, como también que la disposición de las XII Tablas hubiera dado al actor la elección entre el viejo y el nuevo rito (GAYO, IV, 20).

La *condictio*, introducida para las deudas de sumas determinadas de dinero por una *lex Silia* del siglo III a. C., y para las deudas de otras cosas determinadas por una *lex Calpurnia*, poco posterior, se vincula con una disposición de una precedente *lex Pinaria* que había establecido, con respecto a todas las relaciones de deuda y de crédito que se hicieran valer con la *a. sacramenti in personam*, que después de intentada la *legis actio* las partes tuviesen un término de treinta días para volver a comparecer *in iure* y hacerse asignar el juez. Aparte de atenerse a la misma máxima, la *lex Silia* parece haber acogido, pero con modificaciones, también la penalidad que resultaba de la obligación del vencido de pagar la *summa sacramenti*. Según parece, la apuesta de una suma a pagarse al erario fué sustituida por la de pagar una pena

al vencedor del litigio; y la pena se fijó justamente en un tercio de la suma debida (*sponsio et restipulatio tertiae partis*). Pero tal disposición, comprendida quizá en la ley Silia, no fué repetida en la Calpurnia, que no castigaba ya al vencido.

Llamado el deudor ante el magistrado, el actor afirmaba: *Aio te mihi sestertium X milia dare oportere: id postulo aias an neges*. Una respuesta afirmativa habría sido, naturalmente, una *confessio in iure*, con todas sus consecuencias; en cambio, si la respuesta era negativa, el actor agregaba: *Quando tu negas, in diem tricensimum tibi iudicis capiendi causa condico*. Y al trigésimo día las partes volvían a encontrarse ante el pretor para elegir el juez, cuya misión consistía en decidir acerca de la existencia de la deuda.

La acción, que toma el nombre de la palabra *condico* (= te doy cita) pronunciada por el actor, ha sido indudablemente aplicable desde el primer momento al mutuo de dinero o de mercancías. Pero es probable que haya sido aplicada también a la estipulación. Como se ha señalado, este contrato estaba probablemente protegido en los orígenes por la *l. actio sacramenti*, a cuyo lado las XII Tablas habían colocado, para el caso de que las partes lo prefiriesen, el procedimiento menos arriesgado de la *iudicis postulatio*; la ley Silia simplificó el procedimiento más riguroso en el sentido que hemos visto.

Respecto de la *pignoris capio*, refiere GAYO (iv, 29) que fué muy discutida por los juristas su inclusión en el número de las *legis actiones*: ello porque era posible ejercerla fuera del tribunal, y también en ausencia del adversario, y hasta en días nefastos; la opinión afirmativa prevaleció, y justamente porque el *capere pignus* iba acompañado de la pronunciación de palabras solemnes. Como su nombre lo dice, la *pignoris capio* consiste en el acto del acreedor que se apodera de una cosa del deudor que no cumple, para satisfacer con ella su crédito; no sabemos si se hacía propietario de la cosa, o si debía venderla y restituirla luego al deudor la parte del precio que excediera lo necesario para la satisfacción del crédito. De la probable analogía con el procedimiento dispuesto por el tirano Hierón (*lex Hieronica*) y mantenido en vigor por los romanos después de la conquista de Sicilia, se ha inducido que el deudor pudiese oponerse, iniciando un procedimiento declarativo para el desconocimiento de la deuda: si era vencido pagaba el doble, mientras que si el que perdía era

el pretendido acreedor, su responsabilidad se elevaba al cuádruplo. Los casos de aplicación que GAYO enumera en los §§ 27 y 28 se refieren todos a relaciones públicas o sagradas: la pretensión del militar contra el ciudadano que está obligado a suministrarle el *stipendium* o la cebada para el caballo, la que deriva de la venta de un animal destinado a un sacrificio, los créditos de los publicanos en materia de impuestos, y similares.

§ 2. EL PROCESO FORMULARIO

Los elementos caducos en el sistema de la *legis actiones* y el origen del proceso formulario: la *lex Aebutia* y la *lex Iulia iudiciorum privatorum*. Reducción de las acciones a términos formularios. Las *partes formularum*: *intentio*, *demonstratio*, *condemnatio*, *adiudicatio*. La fórmula como medio para la evolución del derecho procesal y material: fórmulas ficticias, con trasposición de condena, *in factum conceptae*. Creación de la *exceptio* y su función: *replicatio*, *duplicatio*, etc. Las *praescriptiones pro actore* y *pro reo*. El proceso *in iure* y la *litis contestatio*; el proceso *apud iudicem*. Medios procesales complementarios: *interdicta*, *in integrum restitutiones*, *stipulationes praetoriae*, *missiones in possessionem*, *bonorum possessiones*.

El sistema descrito de las *legis actiones*, al vincular a las partes y al magistrado a declaraciones predeterminadas e inmutables, presentaba no pocos inconvenientes; sobre todo los de hacer el sistema procesal poco sensible a los cambios de la conciencia jurídica, y quitar al magistrado toda iniciativa. Defecto, este último, que era insoportable en el mundo romano, donde el *imperium* magistratual era comúnmente entendido como ejercicio de poder soberano.

Sin embargo, la opinión ampliamente difundida entre los más recientes estudiosos, de que también en la época del pleno dominio de las *legis actiones* el magistrado jusdicente acostumbra a investir a los jueces del examen de controversias sobre las cuales ni el derecho civil daba normas ni había predispuesto una *legis actio*, carece de todo principio de prueba. En particular, no está demostrado siquiera para un solo caso que el magistrado haya concedido, en semejantes hipótesis, acciones (o *iudicia*) *in factum*, como las que veremos ampliamente difundidas en la época sucesiva. Parece, en cambio, que en el desarrollo mismo de los pro-

cesos declarativos iniciados con *legis actio*, se hubieran ido formando por costumbre ciertas prácticas nuevas, que fueron luego consideradas como el eje del proceso, cuando se presentó la necesidad de organizar, al margen del antiguo sistema, nuevos tipos de procedimiento¹³.

Se ha dicho ya que el procedimiento *in iure* se cerraba con la *litis contestatio*; consistente en la invocación a los presentes para que testificasen *apud iudicem* sobre las *actiones* de las partes y las eventuales providencias del magistrado. Pero es claro que tal institución confiaba excesivamente en la memoria y la buena fe de los testigos. Pese a lo cual era grave interés de las partes que no surgieran oposiciones *apud iudicem*; sobre todo porque una eventual *plus petitio* del actor habría producido el efecto que los romanos expresan con las palabras *causa cadere*, es decir la pérdida de la *litis* y la imposibilidad de reproducirla. En consecuencia, era natural que el actor o persona de su confianza, consignase por escrito los datos fundamentales del proceso *in iure*, y que el escrito fuese, en presencia de testigos, comunicado al demandado y por él reconocido como respondiendo a la verdad, y también sellado cuando el uso de los sellos se difundió en Roma; formalmente, las anotaciones no impedían que *apud iudicem* fuesen examinados los testigos, y que objeto del testimonio fueran las palabras pronunciadas *in iure*; pero el escrito servía de subsidio y de control.

Pero el equilibrio se desplazó en el tribunal del *praetor peregrinus*, en total ventaja del documento, cuando entraron en vigor los negocios del *ius gentium* (cfr. ps. 28 y ss.). La tutela judicial de semejantes negocios no podía, en efecto, desarrollarse en forma de *legis actio*: sea porque, no tratándose la mayoría de las veces de hacer valer negocios pertenecientes al antiguo derecho civil, faltaba la *actio* apropiada, sea porque, teniendo el pretor peregrino una *iurisdictio* limitada a las relaciones entre romanos y extranjeros o entre extranjeros, el principio que excluía a los peregrinos de la *legis actio* no permitía la aplicación de esta forma de proceso. La forma procesal más oportuna fué elegida a imitación de la *actio per iudicis postulationem*: así como podían intentar

¹³ Para cuanto sigue, cfr. ARANCIO-RUIZ, *Le formule con demonstratio e la loro origine*, en los *Studii econ. giur.* de la Universidad de Cagliari, IV, 1912, 2, ps. 75 y ss. (y ahora en *Rariora*, Roma, 1946, ps. 23 y ss.); y HUVELIN, *L'arbitrium liti aestimandae et l'origine de la formule*, en *Mélanges Gérardin*, 1907, ps. 319 y ss.

esta acción los ciudadanos que reconociéndose en relaciones de condominio o comunidad hereditaria, quisieran sustituirla por otros tantos derechos de propiedad exclusiva, se admitió también que las partes de una compraventa o de una sociedad, por ejemplo, pudieran solicitar de común acuerdo al pretor peregrino un juez que resolviera las cuestiones derivadas de su contrato¹⁴. Pero con una diferencia esencial: que mientras las partes en los juicios divisorios tenían a su disposición una *actio* a pronunciar, estos individuos de distinta nacionalidad expresaban sus deseos en la forma, y quizá también en la lengua, que creían más conveniente. De donde la necesidad absoluta de fijar los términos de la controversia en un programa escrito preparado bajo la vigilancia del magistrado. Cuando, con el progreso del tiempo, los negocios del *ius gentium* fueron recibidos en el derecho civil y se hicieron practicables también en las relaciones entre romanos, el pretor urbano no pudo menos que imitar las formas y modos del procedimiento del colega peregrino.

Todo esto fué preparando una reforma general del sistema; en efecto, dos leyes, la *Aebutia* y la *Iulia iudiciorum privatorum*, hicieron que se trasformara en eje del proceso, no ya de hecho sino por derecho, y no ya sólo para algunos procesos sino para todos, el documento en que estaban fijadas las pretensiones de las partes y la misión del juez. En consecuencia, los magistrados judicantes (máxime el pretor urbano) fueron indicando cada año

¹⁴ Sobre esta estructura originaria de los *bonae fidei iudicia*, cfr. mi escrito anteriormente citado. Me parece siempre decisiva, sobre el particular, la construcción de la fórmula que sobrevive en la época clásica (v. más adelante, p. 140); y no me parece que la fuerza probatoria del argumento sea atenuada por las finas observaciones que han hecho en contrario KOSCHAKER ("Rev. Fundac. Savigny", 34, 1913, ps. 433 y ss.; 41, 1920, ps. 338 y s.) y BETTI (*Su la formula del processo civile romano*, en el "Filangieri", 1914, ps. 43 y ss. del extr.). En sustancia, las objeciones de KOSCHAKER se fundan todas sobre construcciones elaboradas por la jurisprudencia romana cuando ya la fórmula se había completado con el *si non paret absolvito*; y en cuanto a BETTI, la traducción por él intentada del *quod* como correspondiente a *cuanto a lo que...*, y, en consecuencia, de toda la frase como no afirmativa de la existencia del contrato sino dirigida solamente a delimitar la tarea del juez, encuentra su refutación en la *demonstratio* de los juicios divisorios, en los cuales no puede negarse que la frase *quod L. Titius C. Seius... iudicem sibi dari postulaverunt* tenga carácter asertivo. En favor de mi tesis está también la analogía, puesta de manifiesto por WEISS ("Rev. Fundac. Savigny", 46, p. 173), de los tribunales mixtos constituidos por tratados entre las distintas ciudades griegas, ante los cuales el demandado no estaba obligado a comparecer.

en el Edicto público en que fijaban los criterios a que se atenderían en el ejercicio de la jurisdicción, los programas típicos de las posibles controversias. A estos módulos se les dió el nombre de *formulae*; al programa preparado sobre su modelo para el planteamiento de la controversia particular, se le dió también algunas veces (aunque impropriamente) el mismo nombre, pero más a menudo y más técnicamente el de *iudicium*. El nombre de *actio*, que ya había designado las solemnes declaraciones de las partes *in iure*, servía ahora para designar ya el *iudicium* mismo (sobre todo en los casos en que se vinculaba a una preexistente *legis actio*), ya toda la actividad desarrollada por el actor para la actuación de su derecho, ya, en fin, la facultad de invitar a la contraparte a aceptar el proceso sobre la base de una fórmula determinada.

De las dos leyes citadas ha sido muy discutida entre los estudiosos tanto la fecha como su contenido preciso. Respecto a la fecha, parece hoy cierto que la *lex Iulia iudiciorum privatorum* sea de Augusto y del año 17 a. C.; en cuanto a la *Aebutia*, todos los datos de las fuentes concurren a hacer considerar que pertenezca aproximadamente al año 120 a. C., porque precisamente a partir de este período están indicadas en nuestras fuentes las fórmulas y los respectivos remedios complementarios. La razón, pues, de que una misma reforma sea atribuida a dos leyes diferentes, y distantes entre ellas en más de un siglo, hay que buscarla probablemente en la circunstancia de que la ley *Aebutia*, ajustándose al principio republicano según el cual la ley no podía abolir las instituciones del antiguo *ius civile*, habría introducido el nuevo tipo de proceso solamente como facultativo, mientras que la segunda habría obligado a los ciudadanos a litigar no más *per legis actiones* sino *per formulas*: obsérvese, sin embargo, que ya en la época ciceroniana (es decir, en tiempo anterior a la *lex Iulia*) el proceso formulario era el más difundido, quizá por ser el preferido por la enorme mayoría de los litigantes.

La fórmula, en la que el nuevo proceso se funda, contiene la pretensión del actor, expresada en términos análogos a aquellos con que era oralmente declarada en la *legis actio*: por ejemplo, y según las denominaciones convencionales que en los módulos preparados por el Edicto pretorio se daban a las partes, "*Numerium Negidium* (demandado) *Aulo Agerio* (actor) *sestertium X*

milia dare oportere", o bien "*a Numerio Negidio... furtum factum esse paterae aureae, ob eamque rem N^m N^m A^o A^o pro fure damnum decidere oportere*"; o bien: "*fundum Capenatem... Auli Agerii esse ex iure Quiritium*", etc. Pero aquí tal declaración es, por lo común, el fundamento de dos períodos hipotéticos, con los cuales el juez es invitado a condenar si la pretensión resulta fundada, a absolver en el caso contrario (si *paret... condemnato*, si *non paret absoluito*), con todas las ulteriores indicaciones que sirven para precisar los límites de la eventual condena.

Así, por ejemplo, la *condictio* de la *lex Silia* se traduce en la fórmula siguiente, llamada ya con el nombre genérico de *condictio*, ya con el más específico de *actio certae creditae pecuniae*:

SI PARET N^m N^m A^o A^o SESTERTIUM X MILLIA DARE OPORTERE, QUA DE RE AGITUR, IUDEX N^m N^m A^o A^o SESTERTIUM X MILLIA CONDEMNATO, SI NON PARET ABSOLVITO;

y la *legis actio sacramenti in rem*, en su principal aplicación de tutela de la propiedad (*rei vindicatio*), se transforma en la fórmula:

SI PARET FUNDUM CAPENATEM, QUO DE AGITUR, A¹ A¹ ESSE EX IURE QUIRITIIUM, NEQUE IS FUNDUS A N^o N^o A^o A^o ARBITRIO TUO RESTITUITUR, QUANTI EA RES ERIT, TANTAE PECUNIAE IUDEX N^m N^m A^o A^o CONDEMNATO, SI NON PARET ABSOLVITO;

y la misión del *iudex postulatus* en una acción *communi dividundo* está expresada del modo siguiente:

QUOD L. TITIVS C. SEIVS DE FUNDI CAPENATE COMMUNI DIVIDENDO IUDICEM SIBI DARI POSTULAVERT, QUIDQUID ADIUDICARI OPORTET IUDEX L. TITIVS C. SEIVS ADIUDICATO, QUANTUM CONDEMNARI OPORTET ALTERUM ALTERI CERTA PECUNIAE CONDEMNATO;

y el programa en el que ya ante el pretor peregrino se fijaba la misión del juez de una *actio empti* (acción intentada por el comprador contra el vendedor), asume esta forma definitiva:

QUOD A^s A^s A N^o N^o HOMINEM STICHUM EMIT, QUA DE RE AGITUR, QUIDQUID OB EAM REM N^m N^m A^o A^o DARE FACERE OPORTET EX FIDE BONA, EIUS IUDEX N^m N^m A^o A^o CONDEMNATO, SI NON PARET ABSOLVITO.

Las fórmulas elegidas como ejemplos permiten destacar los cambios que se han producido en el procedimiento en concomitancia con la reforma fundamental, o como consecuencia de ella. Los procesos que menos gravemente aparecen modificados son los que corresponden a la *condictio* y a los juicios divisorios (primera y tercera fórmula): en el primer caso, el derecho subjetivo invocado

por el actor corresponde exactamente a la eventual condena, que debe consistir en una suma idéntica; en el segundo, el procedimiento concluye, como originariamente, con la adjudicación de partes de la cosa a los copartícipes, y con la eventual condena a pagar sumas compensatorias.

Mucho más modificado queda el trámite del proceso en los casos ejemplificados con la segunda y la cuarta fórmula. El proceso *in rem*, que era doble en los orígenes, en el sentido de que cada una de las partes se declaraba propietaria de la cosa o titular del crédito controvertido, se ha vuelto simple, porque una sola de las partes, el actor, afirma ser propietario y se compromete a probarlo: el actual poseedor toma una posición de defensa y no está obligado a suministrar ninguna prueba de su derecho (cfr. cap. VII, § 3). Además, mientras originariamente el *iudex sacramenti* se limitaba a declarar cuál de las dos partes estaba en lo justo, y sólo en una segunda fase eventual debía ser estimado en dinero el interés del actor en la restitución de la cosa y de los frutos (cfr. p. 132), aquí todo el complejo procedimiento está comprendido en una sola fórmula. El juez deberá examinar antes las pruebas ofrecidas por el actor y las eventuales contrapruebas del demandado, y en el caso de que juzgue fundada la pretensión del primero invitar al segundo a restituir la cosa; después, si éste no accede a tal invitación, deberá valuar la cosa controvertida y pronunciar la condena. Es improbable que todas estas reformas se hayan cumplido por obra de la ley *Aebutia*; pero el nuevo sistema ha favorecido, evidentemente, la fusión de las dos fases en un solo proceso¹⁵.

En cuanto a los *iudicia bonae fidei*, de los que se ha citado como ejemplo la *a. empti*, la reforma principal consistió en sustituir la orden de valuar las pretensiones de las partes (*aestimato*), correspondiente al carácter arbitral del procedimiento iniciado ante el pretor peregrino, por la de condenar o absolver (...*condemnato; si non paret absolvito*). Los rastros del cambio han quedado en la estructura gramatical del programa, que mientras comienza teniendo como indubitado el contrato en virtud del cual

¹⁵ Para los vestigios de una primitiva fórmula de las *actiones in rem*, de carácter adjudicatorio, a la cual por eso debía seguir todavía el procedimiento ejecutivo descrito en la p. 132, cfr. ARANGIO-RUIZ, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 32, 1922, ps. 26 y ss.

se actúa, admite luego con el *si non paret* una eventualidad que parecería ya excluida, es decir, que el contrato no haya tenido lugar: prácticamente, esto sirvió para conseguir que las partes pudiesen ser tuteladas ante los tribunales también cuando estuviese en discusión la existencia del contrato¹⁶.

La reforma de las leyes *Aebutia* y *Iulia*, por la que ya no se tuvieron más unos pocos tipos de declaraciones solemnes a pronunciarse por las partes (*actiones*), adaptables cada uno a una vasta categoría de controversias, sino tantas fórmulas expuestas en el Edicto como fueran las pretensiones típicas reconocidas por el derecho objetivo, produjo también otro resultado, que puede parecer simplemente terminológico, pero que tuvo, en la técnica jurídica, las repercusiones más profundas, ya que las *actiones*, de cinco que eran, se hicieron innumerables¹⁷. No más, por ejemplo, una *actio sacramenti in rem* adaptable a los procesos de propiedad, de herencia, de usufructo, de servidumbre, etc., sino una *rei vindicatio*, una *petitio hereditatis*, una *vindicatio ususfructus*, una *vindicatio servitutis*; no más una *actio per iudicis postulationem*, adaptable a las divisiones de propiedad y de herencia y a la persecución de créditos originados en estipulación, sino una *actio communi dividundo*, una *a. familiae erciscundae*, una *a. ex stipulatu*. Así, derecho y acción se convierten, para los romanos, en las dos caras de la misma medalla, los dos nombres de la misma pretensión; y por eso la necesidad de redactar exactamente las fórmulas condujo al más preciso y delicado examen de los fenómenos jurídicos.

Como se ve por los pocos ejemplos referidos, y como se vería mejor con un examen comparativo de todas las fórmulas conocidas, éstas están todas redactadas según pocos esquemas grama-

¹⁶ Cfr. sobre el particular mi estudio sobre *Le formule con demonstratio*, y *supra*, p. 138, n. 14.

¹⁷ Solamente las dos fórmulas de la *condictio* (*actio certae creditae pecuniae* y *condictio certae rei*) permanecieron ejercibles toda vez que, por causa reconocida por el derecho civil, subsistiese la obligación de transmitir la propiedad de una suma de dinero o de otra cosa determinada; que la obligación derive de un mutuo o de contrato literal o de pago de lo indebido, o aun de otra causa, no hace diferencia. En este sentido, y adaptando por aproximación la terminología moderna de los negocios jurídicos (p. 90), podemos decir que la *condictio* es la única acción formal del derecho romano, mientras que todas las otras acciones son *causales*.

ticales, fácilmente reconocibles. De ahí la posibilidad de analizarlas descomponiéndolas en cláusulas, cada una de las cuales reaparece, con los cambios que la naturaleza de las controversias particulares hace necesarios, en un número indefinido de fórmulas. Estas cláusulas se llaman *intentio*, *demonstratio*, *condemnatio*, *adiudicatio*. Se llama *intentio* la frase con que se expresa la pretensión del actor: por ejemplo, en la *a. certae creditae pecuniae*, la frase ^{Num} ^{Num} *A° A° sestertium X milia dare oportere*, o, en la *rei vindicatio*, la frase *fundum Capenatem... A¹ A¹ esse ex iure Quiritium*. Se llama, en cambio, *demonstratio* la frase en que se detallan los presupuestos de la acción que se intenta, sin la precisa enunciación de un derecho o de una obligación: por ejemplo, en la *a. communi dividundo*, *quod L. Titius C. Seius de fundo Capenate communi dividundo iudicem sibi dari postulaverunt*, o, en la *actio empti*, *Quod A° A° a N° N° hominem Stichum emit*. *Condemnatio* es la frase que inviste al juez del poder de condenar o de absolver, y fija el monto de la condena o el modo de determinarlo: *si paret —*, ^{Num} ^{Num} *A° A° sestertium X milia condemnato*, *si non paret absolvo*; o bien: *si paret —, quanti ea res erit, tantae pecuniae* ^{Num} ^{Num} *A° A° condemnato*, *si non paret absolvo*, y similares. La *adiudicatio* inviste al juez del poder de atribuir a cada una de las partes la propiedad exclusiva de cosas particulares o de porciones de cosas: *quantum adiudicari oportet adiudicato*. *Intentio* y *condemnatio* son *certae* o *incertae*, según que la pretensión del actor o la suma de la condena sean rígidamente fijadas en la fórmula o destinadas a precisarse *apud iudicem*.

Pero no todas estas partes se encuentran en cada fórmula; por el contrario, si tomamos al pie de la letra las definiciones y ejemplos que GAYO da de cada una de ellas, debemos afirmar que no sólo no hay ninguna acción que tenga las cuatro partes indicadas, sino que ninguna parte vuelve a encontrarse necesariamente en cada acción. Sobre la *adiudicatio* y la *demonstratio* no hay por qué insistir; la primera es propia de los juicios divisorios varias veces mencionados; la segunda se encuentra además de en ellos, también en otros juicios en que se trataba (por lo menos en los orígenes) más bien del *quantum* que de la existencia o no de la relación jurídica (juicios de buena fe, acciones derivadas de la estipulación o de legados imperfectamente determinados, etc.). Pero ni siquiera la *condemnatio*, que en una forma u otra se encuentra en los cuatro ejemplos que hemos referido, es indispensable: hay acciones

de mera verificación, generalmente dirigidas a fijar los presupuestos de un juicio futuro y llamadas, por eso, *praeiudicia*, cuya fórmula se reduce a la simple *intentio*: así los pre-juicios *quantum C. Seiae sit*, o *an Titius ingenuus sit*, cuyo programa está todo en las pocas palabras mencionadas.

Mucho más difícil es establecer si hay fórmulas sin *intentio*: por lo común se lo excluye, pero GAYO, cuando ejemplifica la *demonstratio* y la *adiudicatio* en los modos vistos, agota con ellos la fórmula íntegra de los juicios divisorios, aparte de la *condemnatio* final, de manera que no queda lugar para una *intentio*. En otro lugar, a propósito de los juicios de buena fe, considera GAYO como *intentio* la cláusula *quidquid ob eam rem dare facere oportet*; pero, ¿no es ésta, más bien, por su estructura y por el lugar de la fórmula en que figura, una determinación de la *condemnatio*? ¿Y qué hay de diverso entre ella y el *quantum adiudicari oportet* de los juicios divisorios? Ciertamente es que aquella frase no define la pretensión del actor, que se determinará solamente *apud iudicem*, cuando aquél tenga que precisar en qué sentido la contraparte ha faltado a sus obligaciones. En conclusión, y aparte de los esfuerzos de la misma jurisprudencia romana por volver a someter todas las fórmulas bajo el común denominador de la *intentio*, queda una irreductible diversidad de estructura entre las fórmulas directamente cimentadas sobre la existencia de una controversia (*si paret... si non paret...*) y aquellas otras en que la situación recíproca de las partes, aparentemente al menos incontrovertida (*quod* con el indicativo), está dada sólo como presupuesto de una actividad pacificadora del juez.

*
* *
*

Hemos demostrado hasta aquí cómo han pasado bajo los nuevos esquemas, y qué caracteres han asumido, las preterensiones que ya se hacían valer mediante *legis actiones*. Debemos ahora señalar cómo los nuevos medios técnicos han abierto al magistrado el camino para innovar ampliamente en el campo del derecho material; pero tampoco de tales innovaciones, que los romanos expresan con los verbos *adiuvare supplere corrigere ius civile*, podemos indicar en este lugar más que los caracteres formales, ya que las reformas que de ellas resultaron en el derecho material se encontrarán in-

dicadas, cada una en su lugar, en el estudio de las diferentes instituciones del derecho privado.

Ante todo, las fórmulas tuvieron aquella facilidad de adaptación a las hipótesis nuevas que faltaba —como vimos— a las *legis actiones*. Un caso típico se tiene en las fórmulas ficticias, que protegen relaciones desconocidas para el derecho civil, colocándolas bajo el régimen de otras relaciones provistas ya de tutela judicial (cfr. p. 22, n. 4). Por ejemplo, quien ha adquirido una *res mancipi* mediante simple *traditio* no es propietario, y no podría intentar la *rei vindictio*; pero el pretor le concede una acción, llamada *Publiciana*, cuyo juez está obligado a investigar si subsiste la *traditio* sobre la base de una *iusta causa*, y, en caso afirmativo, a proceder como si se hubiese cumplido la usucapción en beneficio del actor.

Otras veces, la fórmula-tipo es modificada por trasposiciones, en el sentido de que mientras la *intentio* menciona como propietaria o como deudora a una persona, la condena es referida a nombre de otra: así, cuando el actor o el demandado es representado por un procurador (p. 155), la exclusión de la representación directa (cfr. *supra*, p. 106) hace que la *condemnatio* recaiga sobre la persona del procurador, mientras que la *intentio* o la *demonstratio* se refieren a la persona del principal; y así también cuando una acción contractual es intentada contra el padre de familia por la deuda del hijo o del esclavo (cfr. ps. 107 y ss.), al nombre del sujeto a potestad indicado en la *intentio* o *demonstratio*, corresponde en la *condemnatio* el nombre del *pater familias*¹⁸.

Con mucha frecuencia, para indicar que una acción es oportunamente aceptada por el pretor con fines distintos de los normales, los jurisconsultos hablan de *actio utilis*. Así, mientras la acción de daño (*actio legis Aquiliae*) corresponde solamente para

¹⁸ En estas hipótesis, las distintas fórmulas reciben también las adiciones necesarias para indicar el especial presupuesto que las hace ejercibles contra el padre de familia (colocación del sujeto a potestad al frente de un comercio marítimo o terrestre, existencia de un peculio, etc.), como así también los eventuales límites de la responsabilidad. Usualmente, antes de decir que corresponde, por ej., la *actio empti* o la *actio locati* o la *actio certae creditae pecuniae* por el hecho del *institor* o en los límites del peculio o análogamente, se dice que corresponde una *actio institoria*, una *a. de peculio*, etc.; pero en estas expresiones debe siempre considerarse sobrentendido el nombre de la acción típica contractual, que caso por caso es adoptada.

los daños causados a cosas corporales con el esfuerzo muscular del agente (*damnum corpore corpori illatum*), se conceden a menudo *utiles actiones legis Aquiliae* a falta de alguno de estos requisitos, especialmente por daño causado *non corpore* (cfr. cap. xvi, § 2). No parece, sin embargo, que la calificación de una acción como *utilis* indique un modo especial de adaptación; por lo menos en términos generales, la adaptación a nuevos fines se consigue mediante ficciones o mediante trasposiciones de condena. En sustancia, cuando se dice que una acción es *ficticia* o que la *condemnatio* figura a un nombre distinto del que lleva la *intentio*, se enuncia un dato de la técnica formularia; en cambio, cuando se afirma que la acción es concedida *utiliter*, se enuncia el resultado práctico que mediante estos retoques se alcanza. Por lo demás, hay que observar que la terminología clásica de la *actio utilis* satisfizo mucho a los compiladores justinianeos, quienes la aplicaron también a hipótesis de su invención.

La actividad reformadora del magistrado se muestra totalmente desplegada en las fórmulas *in factum conceptae*, que son concedidas, por regla, fuera de cualquier referencia, incluso indirecta, a relaciones tuteladas por el derecho civil, pero invitando al juez a condenar o absolver según que se verifiquen o no ciertos presupuestos de hecho. Las acciones *in factum* pueden ser concedidas caso por caso (y la jurisprudencia impulsa a menudo la iniciativa del magistrado, indicando las hipótesis en que la concesión parece conveniente), pero la mayoría de las veces están prometidas en el edicto con cláusulas especiales, seguidas de las fórmulas típicas, y pasando de un pretor a otro adquieren una estabilidad semejante a la de las fórmulas civiles o *in ius conceptae*. Formalmente, la distinción entre uno y otro tipo de fórmulas radica en que, mientras las fórmulas *in ius conceptae* se fundan sobre la afirmación de un derecho subjetivo del actor (*rem Aⁱ Aⁱ esse. A^o A^o ius esse utendi fruendi, etc.*) o de una obligación jurídica del demandado (*N^{um} N^{um} A^o A^o... dare oportere, quidquid... dare facere oportet ex fide bona, etc.*), las fórmulas *in factum conceptae* fundan la condena exclusivamente en circunstancias de hecho. Valga como ejemplo la fórmula *in factum* de la acción de depósito:

SI PARET A^{um} A^{um} APUD N^{um} N^{um} MENSAM ARGENTEAM DEPOSUISSE, EAM QUE DOLO NIALO Nⁱ Nⁱ REDDITAM NON ESSE. QUANTI EA RES ERIT.

TANTAE PECUNIA IUDEX Num Num A° A° CONDEMNATO, SI NON PARET ABSOLVITO; donde se habla sólo del depósito que el actor afirma haber hecho y de la falta de restitución por parte del demandado, sin indicar de ninguna manera que del depósito derive una obligación, un *oportere*. En efecto, no ha nacido una obligación jurídica, porque sólo el derecho civil podría crearla y éste desconoce el depósito; pero la fórmula expedida por el magistrado hace que se verifiquen las mismas consecuencias que se tendrían si hubiese allí una obligación. En definitiva, después de la larga experiencia cumplida a través del edicto traslaticio, la conciencia social terminó por reconocer, sin más, la obligación jurídica; tanto es así que en este caso del depósito y en cualquier otro, a la fórmula *in factum* concedida anteriormente se agregó, con el progreso del tiempo, una fórmula nueva, *in ius concepta*, y precisamente un *bonae fidei iudicium*.

*

* *

Otro efecto de la maleabilidad de la fórmula es el nacimiento de la *exceptio*, cláusula que debe introducirse en el programa judicial a instancias y en interés del demandado, y dirigida a contraponer a la acción una circunstancia que le quita eficacia.

En el sistema de las *legis actiones* se ponía al demandado frente al dilema de confesar que la pretensión del actor era fundada (*confessio in iure*), o de rechazarla lisa y llanamente; porque la deuda, por ejemplo, no hubiese nacido nunca, o porque hubiese sido ya pagada o remitida en forma solemne.

En cambio, en el sistema formulario, a la acción puede oponérsele, por el demandado, la *exceptio*, en virtud de la cual, no obstante el reconocimiento del derecho subjetivo invocado por el actor, el demandado puede ser absuelto.

La base de la *exceptio* está en la oposición que los romanos ven entre los distintos sistemas de normas jurídicas, destinados a actuar cada uno en su propia esfera. Así, se ha señalado (p. 2) que las distintas leyes limitativas y prohibitivas votadas en las asambleas populares no quitaban validez a las normas de la antigua costumbre, sino que representaban solamente convenciones entre los ciudadanos contra ciertos abusos de la costumbre misma. Por eso, por ejemplo, cuando la *lex Plaetoria de circumscriptione*

adolescentium, del 193 ó 192 a. C., prohibió abusar en los negocios jurídicos de la inexperiencia de los menores de veinticinco años, los negocios celebrados con menores de edad permanecieron plenamente válidos, y los acreedores no quedaron impedidos de obrar contra ellos tanto por vía declarativa como ejecutiva; salvo que una acción popular podía, en consecuencia, intentarse contra ellos por violación de la ley, con el efecto de infligírsele una pena pecuniaria. En el sistema formulario se concede al menor de edad mismo, llamado a juicio por el acreedor, una *exceptio legis Plaetoria*, la cual, aunque no niega su deuda, le asegura la absolución si ha habido abuso de su inexperiencia. El mismo desarrollo tuvo lugar para muchas otras prohibiciones y limitaciones legales.

Pero el campo de más amplia aplicación de la *exceptio* lo creó el pretor mismo, quien se sirvió de ella para hacer valer exigencias del sentimiento jurídico en contraste con el derecho civil y no protegidas anteriormente por ninguna otra norma. Así, por ejemplo, a los modos civiles de extinción de las obligaciones, que hacen que el juez de la controversia deba negar, sin más, el *dare* o *facere oportere*, se agregan ahora ciertas circunstancias de hecho que aun no excluyendo el *oportere* permiten, en consideración al sentimiento jurídico, la inserción de una *exceptio*: tal el *pactum de non petendo*, acuerdo por el cual el acreedor se compromete a no requerir la ejecución de la obligación, y del que deriva una *exceptio pacti conventi* (cfr. cap. XVIII, § 1). Análogamente, mientras se mantiene firme la regla de que la simple tradición no basta para transmitir la propiedad sobre las *res Mancipi*, con la consecuencia de que el *tradens* pueda intentar contra el *accipiens* la *rei vindicatio*, tal acción puede ser paralizada por la *exceptio rei venditae et traditae*, siempre que el demandado solicite en tiempo su inserción en la fórmula¹⁹.

¹⁹ En rigor, la excepción no podría llevar más que a rechazar *in toto* la pretensión del actor: sin embargo, hábilmente manejada por el juez, ella puede servir para conciliar de distinto modo los intereses opuestos. Así, cuando el poseedor oponía a la *rei vindicatio* una *exceptio doli* para obtener el reembolso de los gastos necesarios, no contemplaba solamente la hipótesis de que el actor, atemorizado por el fantasma de la excepción, pagase los gastos o renunciase a intentar la acción; porque si así fuese, habría ocurrido que el demandado estuviese en todos los casos convencido *a priori* de que el actor era propietario, y que, por lo demás, fuese indiscutido el monto de los gastos a reembolsar. Más frecuentemente ocurría que el demandado, poco seguro del éxito del

En la fórmula, la excepción toma lugar entre la *intentio* y la *condemnatio*, como una segunda condición (negativa) de esta última; de manera que el juez no sólo debe investigar si subsiste el derecho subjetivo invocado por el actor o la obligación jurídica atribuida al demandado, sino también si subsiste la circunstancia invocada por este último, y únicamente podrá condenar cuando haya dado respuesta afirmativa a la primera cuestión, negativa a la segunda. Así, en los ejemplos dados, la fórmula de la *actio certae creditae pecuniae* (cfr. p. 140) podrá resultar modificada de este modo:

SI PARET Num Num A° A° SESTERTIUM X MILIA DARE OPORTERE NEC INTER Aum Aum ET Num Num CONVENISSE, NE EA PECUNIA PETERETUR, IUDEX Num Num A° A° SESTERTIUM X MILIA CONDEMNATO: SI NON PARET ABSOLVITO,

y la fórmula de la *rei vindicatio*, de este modo:

SI PARET FUNDUM CAPENATEM... Aⁱ Aⁱ ESSE EX IURE QUIRITIIUM, NISI EUM FUNDUM A^{us} A^{us} N° N° VENDIDIT ET TRADIDIT ET NISI IS FUNDUS A N° N° A° A° ARBITRIO TUO RESTITUATUR, etc., etc.

Pero las relaciones entre las partes pueden ser tales que compliquen mayormente la fórmula; se puede suponer, por ejemplo, que la conformidad del actor con el convenio de no pedir, o la venta seguida de tradición, hayan sido arrancadas con violencia o conseguidas con dolo; o que el *pactum de non petendo* haya sido seguido por un nuevo acuerdo, con el cual el deudor hubiera renunciado a la dilación; y podría también este segundo acuerdo haber sido conseguido del demandado mediante dolo. En semejantes hipótesis, después que el demandado hubiera solicitado y obtenido la inserción de la *exceptio* en la fórmula, podría el actor,

juicio sobre la propiedad, plantease como defensa lícita la excepción; después de lo cual el juez, al mismo tiempo en que reconocía la propiedad del actor, ordenaba a éste que se comprometiera a pagar los gastos si quería obtener la restitución de la cosa; solamente si él se negaba a hacerlo, su conducta resultaba dolosa, y el demandado conservaba la cosa y era absuelto. En otros casos, el juego de la *actio* y de la *exceptio* habría conducido a la necesidad de proceder a múltiples transferencias de dinero: para evitarlas, el juez pronunciaba la condena por la diferencia. Sobre estos fenómenos y sobre otros análogos, ver ARANGIO-RUIZ, *L'exceptio in diminuzione della condanna*, Modena, 1930; en cuyos resultados continuó creyendo, no obstante las afectuosas y brillantes críticas de SOLAZZI, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 42, 1934, ps. 268 y ss., y de SEGRÈ, *Scr. giur.*, 2, ps. 475 y ss.

a su vez, requerir la inserción de una *replicatio*, y después todavía el demandado —si fuera del caso— la de una *duplicatio*. Es natural que la eventualidad de estas complicaciones se haga cada vez más rara; GAYO (IV, 128) no va más allá de la *triplicatio* del actor, y otros juristas, que llaman *triplicatio* a la que GAYO califica de *duplicatio*, se detienen en ésta, no por un obstáculo procesal que se oponga a la inserción de nuevas defensas y contraataques, sino por la rareza extrema de situaciones tan complejas, como para justificarlas.

GAYO (IV, 120) divide a las excepciones en *peremptoriae* y *dilatoriae*, y la misma distinción se podría aplicar a las otras cláusulas recordadas. Perentorias son las excepciones que paralizan la acción en cualquier momento en que se intente; dilatorias las que pueden paralizarla por un período determinado de tiempo o en algunas circunstancias, pero que en tiempo posterior o en circunstancias diversas no podrían ya ser opuestas útilmente. Es perentoria, por ejemplo, la *exceptio metus* (cfr. p. 119), y también la *exceptio doli* cuando se funda sobre el *dolus praeteritus* (p. 117).

En cambio, es dilatoria la *exc. pacti conventi*, si el pacto de no pedir fué concluído solamente por tiempo determinado; y así también la *exceptio litis dividuae et rei residuae*, que se puede oponer a quien, después de haber intentado la acción sólo por una parte del crédito, o después de haber intentado sólo algunas entre las varias acciones que le corresponden contra la misma persona, y esto para evitar someterlas a todas al riesgo de un solo proceso, vuelve a presentar la demanda por lo restante dentro del año judicial. Dilatoria la primera porque, transcurrido el tiempo durante el cual el acreedor se había comprometido a no pedir, su acción ya no será paralizada por la excepción; dilatoria la segunda porque, apenas recibido en su cargo el nuevo pretor, le estará permitido obrar de *lite dividua et re residua*. Pero hay que observar que la distinción se refiere solamente a la conveniencia de intentar la acción, no ya a los efectos que tiene la inserción de la *exceptio* en la fórmula; en efecto, es razonable que el actor, viendo oponer al demandado una excepción dilatoria, desista del proceso, postergándolo para mejor oportunidad; pero, en cambio, si persistiese en solicitar la fórmula y el demandado hiciera insertar en ella la *exceptio*, la *litis contestatio* produciría el acostumbrado efecto de la consunción procesal (cfr. p. 153), y la absolución del demandado se pronunciaría con eficacia no provisional sino definitiva.

En interés del actor puede agregarse también la llamada *praescriptio*, consistente en una más precisa determinación de los límites de la controversia, antepuesta a la fórmula y dirigida a evitar que se consideren deducidas en juicio pretensiones que se quiere, en cambio, reservar. Por ejemplo, si ha nacido de un contrato un crédito en cuotas, y éstas se hallan en parte vencidas y en parte no, una acción intentada pura y simplemente consumiría todo el crédito, mientras que la condena se limitaría a las cuotas vencidas, riesgo que el actor puede evitar mediante la *praescriptio* "ea res agatur cuius rei dies fuit".

Al lado de las *praescriptiones pro actore*, GAYO recuerda como ya fuera de uso en su tiempo, las *praescriptiones pro reo* que establecían una reserva en favor del demandado; por ejemplo, la reserva "ea res agatur, si in ea re praeiudicium hereditati non fiat", dirigida a evitar que con motivo de la reivindicación de una cosa particular se decidiera implícitamente la cuestión del derecho a una herencia. GAYO (iv, 133) dice que esta *praescriptio* se había convertido en sus tiempos en una *exceptio*; pero ignoramos si semejantes transformaciones de *praescriptiones* en *exceptiones* son un fenómeno general, y tanto más ignoramos si, precisamente en función análoga a la que en el proceso formulario era propia de la *exceptio*, la *praescriptio* ya se practicase en la época de las *legis actiones*²⁰.

*

* *

Los informes minuciosos y precisos que GAYO nos da en lo que respecta a la estructura de la fórmula, se vuelven mucho más escasos en relación con la marcha del proceso *in iure*. Parece, sin embargo, bastante seguro cuanto sigue.

Formalmente se mantiene la *in ius vocatio*, pero prácticamente se la suele eliminar mediante el *vadimonium*, promesa solemne, garantizada por *vades* y luego por *sponsores* (cfr. ps. 360 y 361)

²⁰ Sobre estos problemas cfr. especialmente WLASSAK, *Der Ursprung der römischen Einrede* [Origen de la excepción romana], Viena, 1910, y "Praescriptio" und bedingter Prozess ["Praescriptio" y proceso condicionado], en "Rev. Fundac. Savigny", 33, 1912, ps. 81 y ss.; PÉTRAU-GAY, *Évolution historique des "exceptions" et des "praescriptiones"*, París, 1916.

de comparecer ante el tribunal en día fijo²¹. En el acto de la *in ius vocatio*, o en el de exigir del demandado el *vadimonium* extrajudicial, el actor le hace conocer la acción que quiere intentar en su contra; es ésta una primera *editio actionis*. Pero, comparecidas ambas partes *in iure* y después de que el actor haya expuesto con palabras libres su pretensión, debe indicar nuevamente, en el Edicto que se halla expuesto en el tribunal, el módulo de acción que entiende adaptar al propio caso, o, si corresponde, declarar en qué modo desea ver modificados los presupuestos fundamentales de este o aquel módulo, para que se haga adaptable a su caso²².

La concesión puede tener lugar sin observaciones por parte del magistrado y sin oposición del demandado; pero puede también desarrollarse *in iure* toda una disputa sobre la conveniencia de esta o de aquella fórmula para la controversia en examen. Disputa que no tiende —entiéndase bien— a establecer si la pretensión del actor es fundada, sino sólo a poner en claro el punto controvertido para establecer qué fórmula ha de convenirle mejor. Por ejemplo, yo actor, solicito la fórmula de la *rei vindicatio*; si el demandado observa que él no disputa de ninguna manera mi propiedad sobre la cosa en cuestión, y que sólo entiende tenerla como usufructuario, el magistrado me niega la *rei vindicatio* para darme en cambio, siempre que yo persista en litigar, la *actio negatoria ususfructus*. Análogas discusiones pueden tener lugar a propósito de las *exceptiones*, *replicationes*, *praescriptiones*, etc. Logrado el acuerdo sobre la fórmula a adoptar como base y sobre el modo de aplicarla al caso concreto, se nombra el juez, en las formas que ya hemos visto al tratar de las *legis actiones* (p. 127), salvo que el *album* respectivo fué cambiado varias veces, ora sustituyéndose a los senadores por los caballeros, ora comprendiéndose en él a los miembros de una y de otra clase, ora agregándose también otras

²¹ En un estadio anterior, y ya en la época de las *legis actiones*, el *vadimonium* servía para deferir un proceso ya iniciado, y consiguientemente se prestaba *in iure*; pero la época clásica está dominada por el *vadimonium* extrajudicial, con el efecto del desuso de la *in ius vocatio*.

²² Sobre la asistencia que los juristas prestan a las partes y al pretor en el procedimiento *in iure*, cfr. WLASSAK, *Die klassische Prozessformel* [La fórmula procesal clásica], en los "Anales Acad. Viena", 1924; y ahora CARRELLI, *La genesi del procedimento formulare*, Milano, 1946, ps. 185 y ss. No es esencial que la solicitud de la fórmula proceda del actor; es más, la estructura del proceso no cambia en los raros casos en que es el demandado quien la pide (el más importante está citado en la p. 159).

categorías. El nombre del juez elegido o aceptado por las partes es indicado en el encabezamiento del *iudicium*, con las palabras *Titius (Octavius, Maevius, etc.) iudex esto*; y el *iudicium*, así perfecto en todas sus partes, es, siempre en presencia del magistrado, recitado por el actor al demandado, que declara aceptarlo. En este *dictare et accipere iudicium* los juristas clásicos reconocen la *litis contestatio*, cuyo efecto principal (al que se vinculan todos los efectos secundarios) consiste en destruir (*consumere*) la relación deducida en juicio y sustituirla por una relación jurídica nueva; esto está indicado por GAYO, considerándolo desde el punto de vista del demandado, con la denominación un tanto singular de *condemnari oportere*; más exactamente se la puede definir como obligación recíproca de aceptar la sentencia del juez (cfr. cap. xiv, § 3, p. 371).

Los datos sumariamente referidos muestran cuán lejos está de la verdad la doctrina, ampliamente sostenida en el siglo XIX y no todavía abandonada por todos, que considera la fórmula (o, más precisamente, el *iudicium*) como una pura y simple instrucción impartida por el magistrado al juez. El desarrollo de la fase *in iure* muestra, en cambio, qué también en esta época el proceso (si bien centralizado en un programa preparado por el pretor) es esencialmente un arbitraje, y que la *litis contestatio* es un contrato, es decir, un negocio jurídico bilateral que obliga al demandado hacia el actor. En este orden de ideas, se considera que los imperativos futuros contenidos en la fórmula (*adiudicato, condemnato, absolutio*) no se los entiende como directamente dirigidos al juez, sino como destinados a describir en tercera persona la conducta que por acuerdo de las partes tendrá que observar el tercero.

Sin embargo, no se puede considerar la fórmula exclusivamente desde el punto de vista del acuerdo entre las partes; si por vía de construcción teórica, y para justificar sus consecuencias sobre las relaciones de derecho material, los juristas indican especialmente el carácter contractual de la *litis contestatio*, el contrato en cuestión es no sólo *recibido* (como se diría hoy, por ejemplo, de un acto notarial), sino *integrado* por la actividad del magistrado. Sobre la fórmula a comunicar al juez deben estar de acuerdo no solamente las partes sino también el pretor, y el acto del magistrado que autoriza la *litis contestatio* no tiene menos valor que la aceptación del demandado. Esta asistencia del magistrado contiene, más bien, en sí misma, dos funciones que varias leyes recuerdan: frente a las partes, ella es un *iudicium dare*

(dar la fórmula); frente al juez, es un *iudicare iubere*, que lo inviste con la función pública, acto que no podría ser cumplido por las partes en litigio, evidentemente no autorizadas para dar órdenes, ni siquiera en tercera persona, a un extraño autorizado como es el juez²³.

De los presupuestos indicados se desprende que ninguno puede ser sujeto a proceso contra su voluntad; si el demandado no comparece *in iure* o no acepta la fórmula que el actor le recita o rehusa algún juez, el magistrado no puede hacer que el proceso tenga lugar. Naturalmente, el demandado está *jurídicamente obligado* a obedecer a la *in ius vocatio*, a comparecer en el término fijado por el *vadimonium*, a aceptar la fórmula que el magistrado estima conveniente y el juez imparcial que se le propone; y si no cumple con estas obligaciones es castigado con sanciones (cfr. p. 162) más temibles que la pérdida de la *litis*. Pero el régimen es muy diferente de aquel al que nuestra mente está habituada.

²³ La doctrina contractual de la *litis contestatio* y de la fórmula ha tenido su apóstol en el lamentado WLASSAK, cuyas críticas a la teoría de la mera instrucción del magistrado al juez han convencido hoy, en los países alemanes como entre nosotros, a casi todos los estudiosos más asiduos del proceso romano (WENGER, KOSCHAKER, PARTSCH, BETTI, etc.). De WLASSAK, véase principalmente el volumen sobre *La litis contestatio en el proceso formulario romano* (1888), y como más reciente, contraponiendo vigorosamente — en oposición con MOMMSEN — la estructura del proceso civil a la del proceso penal, el libro sobre *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer* [Acusación y "litis contestatio" en el derecho criminal de los romanos], en los "Anales Acad. Viena", 1917. El breve escrito de idéntico título, publicado en los "Anales" de 1920 y destinado a rebatir críticas injustificadas, es de una admirable claridad.

En el fondo, también WLASSAK reconocía la existencia de un elemento publicístico, expresado en las palabras *iudicare iubere* (cfr. su volumen sobre *Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse* [La orden de juzgar en los procesos romanos], en los mismos "Anales", 1921); pero para mantener firme el carácter estrictamente privado de la *litis contestatio*, sostenía que el *iussus iudicandi* fuese una especie de decreto, con el anexo de la fórmula ya concordada, decreto que el pretor habría emitido y enviado al juez. Pero de este decreto especial no encuentro rastros: los pasajes en que WLASSAK creía reconocerlo (especialmente la *lex Rubria de Gallia Cisalpina*, ley 21 y ss., y GAYO, IV, 105) prueban más bien, en mi opinión, que el magistrado cumplía precisamente esta función ayudando a las partes en la adaptación de la fórmula, en la elección del juez y en la contestación de la *litis*. Sobre el problema véase ahora la ya citada obra póstuma de O. CARRELLI sobre *La genesi del procedimiento formulare*.

según el cual el proceso es un asunto público, independiente del beneplácito del demandado.

También en aquel solemne negocio jurídico que es el *iudicium* se puede ser, como en general en todos los negocios privados, representado por otros (cfr. p. 105). Al lado de la representación del tutor y del curador, tenemos la del *procurator*, sea *omnium bonorum* (p. 109) o nombrado para el caso (*pr. ad litem*), o hasta que intervenga espontáneamente, sin encargo de la parte interesada (eventualmente ausente); más antigua es la figura del *cognitor*, representante procesal que era designado por el interesado *in iure* con palabras solemnes dirigidas a la contraparte. Como se ha tenido ocasión de decir (p. 145), el principio de exclusión de la representación directa (p. 106) halla expresión en el hecho de que la condena o absolución es ordenada en el *iudicium* y pronunciada por el *iudex*, no en la persona del principal sino en la del *procurator* o *cognitor*; sin embargo, es un principio antiguo el de que, como consecuencia del proceso seguido por un *cognitor*, la *actio iudicati* (cfr. p. 157) se pueda intentar por y contra el principal, y la misma solución fué lentamente extendida, por vía de interpretación o de normas especiales, a vastos grupos de *procuratores*.

Tan solemne y regulado en cada una de sus partes como es el procedimiento *in iure*, es simple, ágil y libre el procedimiento *apud iudicem*, que no requiere ni siquiera la persistencia de aquel acuerdo entre las partes (y en consecuencia, *a fortiori*, la presencia de ambas) que se exige *in iure*; antes bien, si uno de los litigantes no comparece, la *litis* es decidida en favor del otro.

Después de cuánto se ha dicho, no puede considerarse la función del juez como limitada a la resolución de las cuestiones de hecho, como si en la fórmula estuviesen ya resueltas implícitamente todas las cuestiones de derecho; sólo para las acciones *in factum conceptae* se puede decir (y aquí aun dentro de ciertos límites) que las investigaciones de derecho no se presenten *apud iudicem*. Para todas las fórmulas *in ius conceptae*, es el juez quien debe determinar si subsiste el *oportere*, el *ius esse*, el *rem Auli Agerii esse*; lo que importa, por ejemplo, en la *actio certae creditae*

pecuniae, el conocimiento preciso de las diversas hipótesis en que surge la obligación civil de transmitir o restituir una suma de dinero (mutuo, contrato literal, pago de lo indebido, dación ob *turpem causam*, etc.), y en la *rei vindictio*, el conocimiento preciso del complejo régimen de la propiedad romana, especialmente en sus modos de adquisición y de pérdida.

No existen en esta época normas limitativas con relación a las pruebas; las partes y el juez proceden respectivamente a su presentación y apreciación como mejor creen, y a menudo —según la tendencia romana a la oralidad— a las pruebas testimoniales se les reconoce una importancia mayor que a los documentos. La carga de la prueba corresponde, por lo que se refiere a las afirmaciones contenidas en la *intentio* o en la *demonstratio*, al actor; para las circunstancias invocadas en la *exceptio*, al demandado (de donde la regla *reus in excipiendo fit actor*); la alternativa se repite entre *replicatio* y *duplicatio*.

Estimadas las pruebas, agotadas las tentativas de arreglo prescritas o consentidas por la fórmula (cfr., por ejemplo, para la *actio in rem*, la p. 141), el juez dicta la sentencia de absolución o de condena pecuniaria. Entre todas las características del proceso clásico, ninguna es tan notable como ésta de la necesaria pecuniariedad de la condena; importa, sustancialmente, que la demostración suministrada por el actor sobre la existencia de un derecho suyo o de una obligación del demandado no conduzca, sino con el consentimiento del demandado mismo, a la actuación del derecho. Así, el propietario que reivindique su cosa no recuperará la posesión sino en cuanto el poseedor quiera restituírsela, pues de otra manera deberá contentarse con una suma de dinero, pagando la cual el poseedor se transformará él mismo en propietario; y el titular de un crédito que tiene por objeto una cosa determinada, estará siempre sujeto al beneplácito del deudor, que podrá preferir dejarse condenar antes que dar la cosa debida. Técnicamente, es interesante comprobar que si el demandado cumple aun a último momento, con el deber jurídico por el que se ha dejado procesar, la sentencia es de absolución. En realidad, los proculyanos sólo le permitían este cumplimiento tardío en los casos en que la fórmula lo autorizaba más o menos explícitamente; pero prevaleció la opinión de los sabinianos, que en interés común de ambas partes han considerado siempre aplicable la satisfacción en

natura (de allí la máxima, aparentemente paradójica: *omnia iudicia absolutoria esse*).

Para los juicios directamente fundados en las leyes *Aebutia* y *Iulia* (*iudicia legitima*), es decir, para los que tienen lugar entre ciudadanos romanos, ante un juez único y en el radio de una milla desde las puertas de la ciudad, la sentencia debe pronunciarse, por disposición de la *lex Iulia iudiciorum privatorum*, dentro de los dieciocho meses de la *litis contestatio*; velar por que no se incurra en esta caducidad, es interés del actor, el cual, de otra manera, soporta las consecuencias de la consunción de la relación de derecho material que ella produce. En cambio, en los juicios en que falta uno cualquiera de los tres requisitos indicados, y que se consideran instituidos sobre la base del poder discrecional del magistrado (*iudicia quae imperio continentur*), la sentencia debe pronunciarse antes de que cese en su cargo el magistrado que presidió la *litis contestatio*, es decir, dentro del año judicial.

También en lo referente al procedimiento ejecutivo las modificaciones son profundas respecto a la época de las *legis actiones*. Baste decir que la *manus iniectio iudicati* es sustituida por una acción, la *actio iudicati*, con la acostumbrada fórmula propuesta en el *album* y destinada al conocimiento de un nuevo juez. La función práctica de esta acción consiste en permitir una revisión del proceso precedente, para el caso de que no se haya desarrollado regularmente o de que el juez haya abusado de su poder. Pero si el demandado, después de haber aceptado la fórmula de la *a. iudicati*, no llega a demostrar la inexistencia de un juicio regular, la condena se duplica como se duplicaba por la injusta resistencia a la *manus iniectio*; por eso, la mayoría de las veces la *a. iudicati* se extingüía *in iure* con la *confessio* del demandado.

Reconocida por el demandado la condena del primer proceso, o pronunciada por el juez la condena al doble sobre la base de la *a. iudicati*, y transcurridos los acostumbrados treinta días sin que se haya pagado la suma, el actor puede, previa autorización del magistrado, mantener al condenado en custodia, proveyéndole el sustento; pero la deuda se compensa con los servicios que el deudor presta al acreedor, habiéndose abolido las antiguas consecuencias de la *manus iniectio*. Y, por otra parte, también la forma atenuada de ejecución personal queda normalmente eliminada con la solicitud que el acreedor hace de resarcirse sobre el patrimonio del

deudor, a través de aquella *missio in bona* de que se hablará dentro de poco (ps. 162 y ss.).

*
* *

En menos directa vinculación con la imponente reforma producida por las leyes *Aebutia* y *Iulia*, pero dependiendo siempre de la amplitud de poderes reconocidos a fines de la época republicana al magistrado jusdicente, están otros medios procesales que sirven de complemento al sistema de las acciones: tales los *interdicta*, las *in integrum restitutiones*, las *stipulationes praetoriae*, las *missiones in possessionem*, las *bonorum possessiones*; medios que muchas veces están en función el uno del otro, y ayudan al desarrollo del proceso ordinario²⁴.

Los *interdicta*²⁵ son órdenes que el pretor expide, de conformidad con los módulos expuestos en el Edicto y a instancia del interesado o (en caso de interés público) de cualquier ciudadano, para disponer ya la exhibición de cosas o personas, ya la restitución de cosas o destrucción de obras, ya la abstención de determinados actos: de aquí la distinción fundamental entre *interdictos exhibitorios*, *restitutorios* y *prohibitorios*. La orden, que se dirige siempre a una o más personas determinadas, no presume, sin embargo, una previa verificación del interés legítimo del recurrente y de estar la contraparte en condiciones de satisfacerlo; antes bien, la forma misma es tan abstracta que el destinatario sólo puede sentirse afectado si su conducta es verdaderamente contraria a la actitud que el pretor requiere. Valgan como ejemplo:

1º) el *interdictum* (exhibitorio) *de homine libero exhibendo*: "Quem liberum dolo malo retines, exhibeas" (si el hombre de quien se trata es o no libre, si hay o no hay dolo en retenerlo, lo dirá el destinatario);

2º) el *interdictum* (restitutorio) *quorum bonorum*: "Quorum bonorum ex edicto meo illi (nombre del recurrente) possessio data

²⁴ Hablando de estos medios como propios del sistema formulario, no entiendo tomar posición decidida contra los que consideran ya existente en la época de las *legis actiones* éste y aquél entre ellos (y los *interdicta* especialmente); considero, sin embargo, que todavía no se ha suministrado la demostración.

²⁵ Sobre el tema: BISCARDI, *La protezione interdittale nel proc. rom.*, Padova, 1937.

est, quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides... quodque dolo malo fecisti uti desineres possidere, id illi restituas" (donde también corresponde al destinatario meditar sobre si la *bonorum possessio* ha sido justamente concedida al recurrente, y si uno u otro bien ha sido poseído por él, destinatario);

3º) el *interdictum* (prohibitorio) *ne quid in loco publico fiat*: "ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur praeterquam quod lege senatus consulto... tibi concessum est" (donde la formulación es tan rica en condiciones y en reservas que se excluye de modo absoluto la posibilidad de que el pretor practique, antes de dictar la prohibición, todas las investigaciones oportunas).

La rapidez con que la orden del magistrado, por provisional que fuese, seguía a la denuncia de la violación bastaba, la mayor parte de las veces, para alcanzar el propósito perseguido: todo destinatario habrá meditado, en efecto, sobre su propia conducta, y evitado persistir en un comportamiento cuyos peligros le eran muy claros. Solamente en caso de vacilación o rebeldía del demandado, o si éste creía estar en su derecho, la decisión de la cuestión tenía lugar en un estadio sucesivo, a través de un proceso regular.

Este proceso es de dos especies: *cum poena* o *sine poena* (GAYO, IV, 141); pero la segunda alternativa es propia de los interdictos exhibitorios y restitutorios, mientras que los prohibitorios (que constituyen la mayoría) sólo admiten el procedimiento *cum poena*.

El destinatario de un interdicto exhibitorio o restitutorio, que podría, como hemos dicho, en plena conciencia de la obligación que sobre él pesa, exhibir o restituir lisa y llanamente, puede también, aun con la más buena voluntad de obedecer, tener dudas sobre su obligación o sobre la extensión de aquélla. En este caso puede, apenas se le haga conocer la orden y antes de salir del tribunal, solicitar y hacer aceptar por el interesado la llamada *fórmula arbitraria*; el juez elegido en el acto de la *litis contestatio* examinará la cuestión y —si lo considera del caso— lo invitará a ponerse en regla, con la salvedad de condenarlo en dinero si en este punto desaparece la buena voluntad. En cambio, si el demandado no solicita la *fórmula arbitraria* ni cumple lisa y llanamente la orden del magistrado, quien solicitó la concesión del interdicto puede volver a llamar *in ius* al destinatario y constreñirlo allí a

prometer, con una *sponsio*, una suma de dinero para el caso de que hubiera actuado contra la orden del magistrado (es decir, que la conducta por él observada caiga en el ámbito del abstracto mandamiento pretorio); a su vez, el destinatario exigirá de la otra parte (con una *restipulatio*) la promesa de idéntica suma para el caso de que la desobediencia no exista. De las dos promesas nacen dos acciones iguales y contrarias, expresadas en la fórmula de la *actio ex stipulatu certi* (cfr. p. 365); una tercera fórmula, que el actor se hace dar simultáneamente con la primera, contempla el objeto propiamente dicho de la controversia, es decir, la exhibición o restitución a cumplir, o la conducta injusta a suprimir, y su eventual estimación en dinero. El destinatario absuelto en la sentencia sobre la *summa sponsionis*, será también naturalmente absuelto en la que se refiere a la sustancia de la *litis*, y podrá exigir la *summa restipulationis* a que la otra parte es condenada; si es condenado al pago de la *summa sponsionis* podrá evitar, por lo común, la condena que lo amenaza sobre la base de la tercera fórmula, observando finalmente, o comprometiéndose a observar, la conducta que no ha tenido antes.

El procedimiento es todavía más complejo en los llamados *interdicta duplicia*, que tienen lugar cuando la orden del magistrado se dirige a ambas partes, de modo que cada una puede acusar a la otra de haberla violado (tal el *int. uti possidetis*, cfr. cap. XI, § 2); en semejantes casos se cruzan dos *sponsiones* y dos *restipulationes*, de las que nacen cuatro acciones *ex stipulatu*, aparte de la acción decisiva con que se liquida la cuestión fundamental.

La *in integrum restitutio* es una decisión del magistrado que reduce a la nada un acto jurídico cualquiera, material o procesal; tiene lugar *causa cognita*, es decir, sobre la base de una estimación de la importancia de las circunstancias invocadas, y en hipótesis que están genéricamente contempladas en el Edicto. No parece necesario que el magistrado emita un decreto especial; la mayoría de las veces, la *restitutio* va implícita en la redacción de una *formula ficticia*, por la cual el juez debe considerar como no sucedido el hecho que habría impedido la acción, o bien en la concesión de una *exceptio* al demandado²⁶. La *restitutio* tiene lugar, como

²⁶ Cfr.: LAURIA, *Studi Bonfante*, II, ps. 513 y ss., cuya opinión me parece resistir a la revisión de CARRELLI, "Annali Fac. Giur. Bari", 1938, ps. 129 y ss.

sabemos, en caso de violencia (*supra*, p. 119); pero también se aplicó a los contratos concluidos por los menores de 25 años, a las obligaciones extinguidas por *capitis deminutio* del deudor (por ejemplo, si un padre de familia se hubiese hecho adoptar [*adrogare*], o una mujer no sujeta a la patria potestad hubiese caído *in manum mariti*), y a otros casos análogos. A veces, la *in integrum restitutio* elimina los efectos de la *litis contestatio*, haciendo revivir la relación deducida en juicio; si, por ejemplo, por un error excusable el demandado no ha opuesto excepciones perentorias que estaban a su disposición, el pretor puede restituirlo *in integrum*, y el proceso recomenzará desde el principio.

Se llaman *stipulationes praetoriae* ciertas promesas solemnes que los ciudadanos pueden ser constreñidos a formular ante el tribunal del magistrado; sea con el fin de reforzar una obligación jurídica ya existente, sea —y más a menudo— para crear una nueva obligación en defensa de un interés no tutelado de otra manera. Cuando constan de la sola promesa de quien debe observar la conducta querida, se llaman *repromisiones*; cuando en ellas intervienen garantes, *satisfactiones*; el nombre de *cautio* se aplica indiferentemente a una y otra hipótesis. Ejemplos típicos de estipulaciones pretorias son: las *satisfactiones* que el demandado puede ser obligado a prestar para la ejecución de la eventual condena (*cc. pro praede litis et vindictiarum* y *iudicatum solvi*); la *cautio ratam rem haberi*, con la que el procurador que representa a otro en juicio toma sobre sí la responsabilidad de la aceptación de las consecuencias de la *litis* por parte del principal; la *cautio damni infecti*, que los propietarios de inmuebles deben prestar cuando las condiciones de los inmuebles mismos o las construcciones de obras nuevas amenacen causar daño a las propiedades vecinas. A la imposibilidad de una coerción material para la obtención de la promesa suple la coacción indirecta; así, el demandado por una *actio in rem*, si no presta la *satisfactio pro praede* o *iudicatum solvi*, es privado de la posesión, con lo cual el demandado se transforma en actor e incurre en la carga de la prueba; y otras veces, como en el caso de la *cautio damni infecti*, el pretor ofrece una *missio in possessionem* a aquel que no ha podido obtener la deseada promesa.

Este último nombre es el que se da a un acto de autoridad con el cual el magistrado, según criterios fijados en el Edicto, pone

a individuos particulares en la tenencia o en la posesión propiamente dicha de determinados bienes o conjuntos de bienes, por tiempo más o menos largo, y con poderes de control, de administración, de disposición, que varían de caso a caso; según que la *missio* comprenda un objeto particular o un patrimonio, se habla de *missio in rem* o de *missio in bona*.

El caso más notable de *missio in bona* tiene lugar con relación al deudor que no hace frente a sus compromisos²⁷. El Edicto contempló quizá por primera vez la hipótesis del deudor que *fraudationes causa latitat*, es decir, que se sustrae a la *vocatio in ius*; pero muy pronto consideró también la del ausente que no se hace representar, la de aquel que sin razón se rehusa a la *litis contestatio*, la del deudor muerto sin herederos. Y, en fin, se admitió que contra el deudor condenado el acreedor renunciase a la ejecución personal (cfr. p. 157) para proceder sobre los bienes. Los acreedores (no sólo aquellos que desde el principio lo solicitan, sino también los que acceden sucesivamente) son colocados por el pretor en posesión del patrimonio del insolvente; uno de ellos, a quien el pretor nombra curador, tiene la custodia de los bienes y la obligación de anunciar por proclamas públicas la *missio* conseguida. Trascurridos treinta o quince días desde esta *missio*, según que el procedimiento se refiera a los bienes de una persona viva o de un difunto, los acreedores nombran de su seno un *magister*, quien, efectuado el inventario de los bienes, publica un bando (*lex venditionis*), y después de quince o diez días procede a la venta, adjudicando todo el activo, en bloque, a quien ofrezca a los acreedores el más alto porcentaje sobre los créditos. Al adquirente (*bonorum emptor*) se lo considera sucesor (a título universal, cfr. p. 41) del deudor: está tutelado en el goce de los bienes con un interdicto especial, y puede obrar contra los eventuales deudores del insolvente o (si éste es difunto o *capite minutus*) con una acción ficticia que lo equipara al heredero (*a. Serviana*). o de otra manera con una fórmula que lleva en la *intentio* el nombre del insolvente y en la *condemnatio* el suyo (*a. Rutiliana*).

Este procedimiento puede verse complicado por la necesidad de reparar las disminuciones que el patrimonio del deudor haya

²⁷ Sobre esta materia son ahora fundamentales los cuatro cursos de SOLAZZI, *Il concorso dei creditori in dir. rom.*, Napoli, 1937-1943.

sufrido en virtud de actos por él realizados en fraude de los acreedores, enajenando este o aquel bien. A la revocación de estos actos fraudulentos tienden, en el derecho clásico, diversos medios: ante todo un *interdictum fraudatorium*, que impone al adquirente la restitución de cuanto ha recibido; además, según parecería menos improbable, una *restitutio in integrum*, que vuelve las cosas al estado en que se hallarían si la enajenación no hubiese tenido lugar. Los justinianeos sustituyen a estos distintos medios una acción *in factum*, designada a veces con el nombre de pauliana; se discute si ésta fué para los clásicos un medio judicial autónomo, o si fué el nombre especial de la fórmula arbitraria ofrecida por el Edicto al destinatario del *int. fraudatorium*, o el de la acción (rescisorio) que el pretor daba al *bonorum emptor* en contra del poseedor en aplicación de la *in integrum restitutio*. Igualmente controvertidos son los límites de competencia de los distintos medios, y el modo como se concilian entre ellos²⁸. No menos graves son los problemas suscitados por los presupuestos generales de la revocación. Se puede dudar, por un lado, si al hablar de *fraudari*, *fraudator*, *gestum fraudationis causa*, se alude a un particular elemento intencional, o a la sola conciencia de perjudicar con la enajenación a los acreedores. En cuanto a la situación del tercero adquirente, el derecho justiniano distingue entre adquisición a título oneroso y a título gratuito, y sólo en la primera hipótesis exige que el tercero tenga conocimiento del fraude (para la dote,

²⁸ Sobre el tema, cfr. en particular las distintas ediciones del *Edictum perpetuum* de LENEL, que dan soluciones bastante divergentes, y del mismo autor *Die Anfechtung von Rechtshandlungen des Schuldners...* [La revocación de actos jurídicos del deudor en el derecho romano clásico], en *Festgabe für A. Schultze* [Estudios en honor de A. Schultze], Leipzig, 1903; y los amplios y múltiples estudios de SOLAZZI, esp. en "Studi e Doc. di Storia e Diritto", 22, 1901, ps. 315 y ss.; 23, 1902, ps. 161 y ss.; y en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 15, 1903, ps. 127 y ss.; cfr., por último, *La revoca degli a. fr.*, 3ª ed. en 2 vols., Napoli, 1945. El lamentado COLLINET ("Nouv. Rev. Hist.", 43, 1919, ps. 187 y ss.) intentó demostrar que el nombre de la *a. Pauliana*, que aparece en un solo fragmento del Digesto (22, 1, 38 § 4) y en algún texto bizantino, no sea clásico, y tampoco justiniano, sino que se haya introducido en la ley 38 § 4, por vía de glosa posjustiniana. Pero la demostración no parece lograda: cfr., por último, SOLAZZI, *Revoca*, ps. 66 y ss., que considera justiniano el nombre de la Pauliana. Discutible es, también, la clasicidad del adjetivo *fraudatorium*, con el cual se califica al interdicto: cfr. BESELER, "Rev. Fundac. Sav.", 56, 1936, p. 81; SEGRE, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 48, 1941, ps. 38 y ss.; SOLAZZI, *Revoca*, ps. 94 y ss.

que se considera adquisición a título oneroso para el marido, a título gratuito cuando vuelve a la mujer, el conocimiento del fraude sólo se requiere si no le ha sido todavía restituída a esta última); quizá para el derecho clásico estuviera a discreción del pretor conceder o no el medio revocatorio contra el donatario no partícipe del fraude.

El procedimiento descrito es atenuado en la llamada *bonorum distractio*, que tiene lugar cuando los bienes se venden al detalle, en los límites en que la liquidación resulta necesaria para la satisfacción de los acreedores; el deudor se libera en tal caso de la infamia que deriva de la *bonorum venditio* ordinaria. Existe un caso seguro de aplicación de la *distractio* en favor de los senadores; pero es muy probable que se aplicase también cuando el insolvente era un pupilo o un *furiosus*²⁹.

Además, sobre la base de una ley Julia, que es quizá un capítulo de la ley *Augustea iudiciorum privatorum* (cfr. p. 138), el deudor puede evitar, ya la ejecución personal, ya la infamia que derivaría de la *bonorum venditio*, cediendo voluntariamente los bienes a los acreedores³⁰.

Entre los medios judiciales complementarios corresponde, en fin, recordar la *bonorum possessio*, consistente en la atribución del señorío de hecho sobre los bienes de un ciudadano difunto a personas que a primera vista se presentan como los más probables herederos, o directamente (en el desarrollo que la institución fué adquiriendo) a personas distintas de aquellas a las que el derecho civil considera herederas. Señorío que fué al principio provisional, en el sentido de que el verdadero heredero podía siempre recuperar los bienes demostrando su calidad de tal (*bonorum possessio sine re*); pero que luego fué en muchos casos protegido por el pretor mediante excepciones y acciones ficticias, incluso contra el propio heredero (b. p. *cum re*): cfr. ps. 584 y ss., y *passim* en el cap. XXV.

²⁹ SOLAZZI, *Un caso de distr. bon. nel dir. rom. class.*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 16, 1904, ps. 89 y ss.; *Concorso dei creditori*, III, ps. 1 y ss.

³⁰ Sobre las condiciones de este beneficio cfr., en diverso sentido, WLASSAK, *Cessio bonorum*, en la *Enciclop. dell'antichità class.* de PAULY y WISSOWA, III, 1995 y ss.; ZANZUCCHI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 29, 1918, ps. 71 y ss.; SOLAZZI, *Concorso*, IV, ps. 130 y ss.

§ 3. LA "COGNITIO EXTRA ORDINEM" Y EL PROCESO POSCLÁSICO

La *cognitio extra ordinem* en el proceso romano y en el de las provincias: decadencia del *iudex privatus* y de las fórmulas. Los distintos tipos de introducción de la *litis* en la época posclásica: la *litis denuntiatio*, el *libellus conventionis* y la transformación de la *litis contestatio*. Principios fundamentales del proceso justiniano: ordenamiento judicial; introducción y desarrollo del juicio; sistema de las pruebas; procedimiento de segunda instancia; ejecución. Procedimiento contumacial. Procedimientos especiales: proceso *per rescriptum*, *summatim cognoscere*, *episcopalis audientia*.

El proceso *per formulas*, que hasta aquí hemos descrito, y que es la institución más característica y más técnicamente refinada del derecho romano, no es, sin embargo, el único tipo de proceso entre particulares que conoce la edad clásica; por el contrario, en toda la pureza de sus líneas, él halla aplicación en los primeros siglos del Imperio, sólo en la ciudad de Roma y en el reducido territorio en que tiene competencia exclusiva el *praetor urbanus*, y aun en la capital es solamente proceso ordinario (*ordo iudiciorum*), al que se contrapone, en un campo que es al principio limitadísimo pero que continuamente se extiende, una *cognitio extra ordinem*.

Ya en los últimos siglos de la República se deciden *extra ordinem* (es decir, sin observar las normas del proceso formulario) cuestiones de carácter administrativo en las que el Estado, como muchas veces se ha señalado (ps. 34 y 78), afirma frente al particular la propia supremacía; en tales hipótesis, es el mismo magistrado autor del acto administrativo (por ejemplo, el censor), quien puede, a instancia del interesado, volver sobre su propia actuación y dictar nuevas providencias. Pero desde el tiempo de Augusto también varias relaciones entre particulares, que en el *ordo iudiciorum* no encontraban tutela jurídica o para las cuales se consideraba oportuna una más amplia discrecionalidad del juez, fueron sujetas a un juicio libre cuya característica esencial consistió en la eliminación de la distinción entre el procedimiento *in iure* y el *apud iudicem*, de modo que la controversia era decidida por el magistrado mismo; así se defirieron a un pretor especial (*praetor fideicommissarius*) las cuestiones derivadas de los fideicomisos, disposiciones de última voluntad en forma de ruegos

o recomendaciones a los herederos o legatarios, que los príncipes consideraron dignas de protección cuando el incumplimiento apareciese particularmente irrespetuoso de la fe del testador (cfr. cap. xxvi); otro pretor fué investido del conocimiento *extra ordinem* de los procesos de libertad y esclavitud (*liberales causae*); y las numerosas cuestiones derivadas de la tutela fueron al principio deferidas a los cónsules, y después también a un pretor especial, *tutelarius* o *tutelar*.

Más ampliamente influyó sobre la transformación del procedimiento el régimen de la *appellatio*. Mientras el proceso privado de la época republicana se desarrollaba en instancia única, y contra la sentencia no existían recursos ordinarios³¹, desde el comienzo del Principado se reconoció al emperador el derecho de reformar las decisiones contra las cuales el vencido hubiese apelado ante él; y no sólo, según parece, las decisiones procedentes de otras *cognitiones extra ordinem*, sino también las sentencias de *iudices privati*. De excepcional que era en los orígenes, el ejercicio de esta facultad del príncipe se hizo normal, y funcionarios por él delegados fueron asumiendo como competencia estable la de decidir en grado de apelación las controversias entre particulares.

Sin embargo, el régimen de la *cognitio* permaneció, en Roma y en Italia, como una excepción, superada por la preeminencia del proceso formulario; prueba tangible de ello es la actividad de la jurisprudencia clásica, que hasta el siglo III d. C. continuó gravitando en torno al Edicto Perpetuo y a las fórmulas allí propuestas. Pero la tenacidad con que la casta de los jurisperitos se encerró en el estudio práctico y doctrinal del derecho aplicado en la capital, no debe hacer olvidar el trabajo de resquebrajamiento de las instituciones clásicas que también por esta parte se venía cumpliendo en las provincias del vasto Imperio³².

³¹ No es tal la *restitutio in integrum* (p. 160) concedida en hipótesis particulares, y que, si también es aplicable a la sentencia dictada (lo que algunos niegan), no la reforma sino que la anula. Igualmente se ha visto (p. 157) que la resistencia del demandado frente a la *a. iudicati* puede llevar a considerar no dictada la sentencia ilegal (por ejemplo, por vicio del procedimiento *in iure*, o por inobservancia por parte del juez del *iudicium* sobre el cual se acreditó la litis.

³² Sobre cuanto sigue, cfr. especialmente Wlassak, *Zum römischen Provinzialprozess* [Sobre el proceso provincial romano], en los "Analecta Acad. Viena", 1919.

En las provincias, en efecto, desaparece aquella división de competencias que en Roma mantenía netamente separados los dos campos del *ordo iudiciorum* y de la *cognitio extra ordinem*; antes bien, funciones jurisdiccionales y funciones administrativas, jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales, se suman en un sólo funcionario: el procónsul de las provincias senatoriales o el *legatus Augusti pro praetore* de las provincias imperiales. Frente al régimen formulario parece que la situación fuera diferente según que la provincia fuese senatorial o imperial, en el sentido de que solamente los magistrados de orden senatorial que rigen las provincias de la primera especie tendrían una jurisdicción conforme a la del pretor romano, y en consecuencia la competencia para publicar un Edicto redactado sobre el modelo del de la madre patria; mientras que a los funcionarios que el emperador pone al frente de las provincias de su pertenencia, escogiéndolos dentro del orden de los caballeros, se les negaría tal competencia. De todos modos, unos y otros gobernadores tienen una competencia procesal muy vasta: los ciudadanos romanos residentes llevan a su conocimiento tanto las controversias que en la ciudad se desarrollarían *per formulas*, como las que se decidirían *extra ordinem*, y además se les defiere, por lo menos en última instancia y para los casos de mayor importancia, el conocimiento de las controversias entre los naturales de las provincias, a decidirse fuera de toda vinculación con el derecho romano y con el *ordo iudiciorum*. En estas condiciones era inevitable que un tipo de proceso influyera sobre el otro, y puesto que la exigencia que menos frecuentemente se presentaba y a la que debía ser más reacio el ambiente provincial era la del acuerdo de las partes sobre el nombre del juez y su elección dentro de un *album* preestablecido en el tribunal, fué precisamente el típico *iudex privatus* del proceso clásico el primero en desaparecer. No es que el presidente de la provincia decidiese personalmente todas las controversias, puesto que solía valerse ampliamente de la facultad de delegar su conocimiento en otros; pero el juez delegado no era elegido por las partes, y, aunque aceptado por ellas, su poder de juzgar no derivaba del acuerdo entre los contendientes sino exclusivamente de la investidura del presidente, y no era por lo común un ciudadano particular sino un funcionario administrativo jerárquicamente dependiente del gobernador que lo delegaba para juzgar; en fin, no era siempre nombrado para la decisión de una *litis* ya plantea-

da y contestada, sino delegado, la mayoría de las veces, para todo el desarrollo del proceso, sin consideración alguna de la distinción entre las fases que en Roma se habrían desarrollado *in iure* y *apud iudicem*.

Esta alteración, que desnaturaliza el proceso privado clásico, parece haberse cumplido dentro del primer siglo de la era vulgar (o imperial); pero no parece que haya destruido, por lo menos para las provincias senatoriales y para las controversias entre romanos incluidos en el *ordo iudiciorum*, los que eran verdaderos puntos cardinales del sistema formulario; es decir, el mismo *iudicium*, como programa escrito sobre el cual las partes se ponían de acuerdo, y la *litis contestatio*, consistente en la recitación y aceptación del *iudicium* y que producía la consunción de la relación material que en el mismo *iudicium* se trasfundía. Mucho menos desaparecía en Italia el proceso formulario, aunque también respecto al territorio de la península y siempre exceptuando a la capital, las investigaciones más recientes tiendan a admitir la formación de un tipo de proceso semipúblico, conducido desde el principio hasta el fin bajo la dirección de funcionarios (los *iuridici* instituidos por Marco Aurelio) o de sus delegados. Pero la desaparición de la distinción entre los estadios *in iure* y *apud iudicem* hizo que el acuerdo de las partes sobre la fórmula fuese cada vez más desprovisto de la posición señalada y dominante que había tenido en el proceso más típicamente romano; y que frente a él tomaran cada vez mayor importancia las peticiones escritas que las partes presentaban a la autoridad y la discusión que sobre estas peticiones se planteaba. Conocemos con precisión el desenlace de este desarrollo histórico, cuyos detalles nos escapan: una constitución de Constancio y Constante, del año 342, que abolió las fórmulas, describiéndolas como redes insidiosas en las que se enmarañaba la buena fe de las partes³³.

Así el procedimiento *extra ordinem*, aun conservando su viejo nombre, se convertía en la única forma de proceso civil.

Una de las principales características de este proceso es la intervención del magistrado, o en general de la autoridad pública, en la actividad que el actor despliega para asegurarse la presencia del demandado en el tribunal. Los juristas romanos, habituados

³³ C. 2, 57, 1: "Turis formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicitus amputentur".

a los 'medios estrictamente privados de la *in ius vocatio* y del *vadimonium*, parecen advertir en materia de *cognitio extra ordinem* una sustitución propiamente dicha de los órganos del Estado al actor; y, en efecto, la palabra *evocatio*, por ellos usada a este respecto, aludiría a un mero mandato de la autoridad, al que el demandado debiera obedecer. Pero los juristas mismos advierten que la forma de tal *evocatio* es triple: *edictis litteris denuntiationibus*; y de éstas sólo la primera, que es la menos usada, puede ser considerada como un simple acto de la autoridad. Ya en la *evocatio litteris* aplicada más bien a procedimientos de jurisdicción voluntaria (como la dación de tutores) antes que a verdaderas controversias, es el interesado quien impetra del magistrado la concesión de la carta de citación y se ocupa de su entrega a la contraparte. Y en la *evocatio denuntiationibus*, que es la más frecuente (tenemos ejemplos preciosos en los papiros greco-egipcios del siglo I al siglo III), es el actor quien remite al funcionario regional (στρατηγός) la intimación para que el demandado comparezca en la plaza principal del distrito mismo, en los días en que el prefecto administrará allí justicia (*conventus*) y el funcionario no hace más que trasmitirla por medio de un dependiente suyo.

De estos precedentes, especialmente provinciales, de la época clásica, descende directamente, como lo va reconociendo la doctrina, la *litis denuntiatio* regulada por Constantino en C. Th. 2, 4, 2; es más: el fin de la constitución citada parece haber sido solamente abolir la *privata testatio*, invitación dirigida por el actor al demandado sin intervención de la autoridad, que se había ido difundiendo, especialmente en Italia, fuera de toda sanción legal. La *litis denuntiatio* constantiniana es una declaración del actor, dirigida al demandado pero redactada con la cooperación de un funcionario autorizado para recibir tales declaraciones; sólo en época posterior el funcionario que recibe la *denuntiatio* se identifica con el juez a quien corresponde la decisión de la controversia. Desde la denuncia transcurre un término de cuatro meses, a cuyo vencimiento las partes tienen la obligación de comparecer en juicio, bajo pena de la pérdida de la *litis* (si falta el actor) o del proceso en contumacia (si quien falta es el demandado); sin embargo, el actor puede obtener, justificando la falta de comparecencia, una *reparatio temporum*.